

pública, razón por la que fueron denominadas como sanitarias, además de que se encontraban incluidas en códigos y reglamentos de este tipo (1).

La cuestión ecológica hace que las instituciones clásicas del derecho disfuncionen. Las soluciones habituales del Derecho son insuficientes e inadecuadas para dar respuesta a la problemática ambiental, por que es diferente a la problemática general (2).

El sistema del Derecho venido del siglo XIX está pensado para resolver situaciones individuales. Sin embargo, el Derecho Ambiental es de incidencia colectiva, de interés difuso, está huérfano de los casilleros tradicionales. Es de orden público; se cruza el Derecho Ambiental con el Derecho a la vida y a la salud. Es Derecho Privado y Público. Es Derecho Humano personal, un presupuesto del desarrollo humano, y al mismo tiempo un Derecho social, de masas.

Derecho Ambiental es un derecho que está en formación, está en una etapa de desarrollo, de manera que podemos decir que es un derecho nuevo. Corresponde recordar en este inicio que el derecho ambiental, disciplina jurídica en pleno desarrollo y evolución, constituye el conjunto de normas regulatorias de relaciones de derecho público o privado tendientes a disciplinar las conductas en orden al uso racional y conservación del medio ambiente, en cuanto a la prevención de daños al mismo, a fin de lograr el mantenimiento del equilibrio natural, lo que redundará en una optimización de la calidad de vida.

Es que el derecho ambiental, "el otro yo orteguiano", supone, indisolublemente, el derecho a la vida, a la salud, implica una gran aproximación de lo privado a lo público, o dicho de otra manera, "la vida privada se tiñe de pública".

De lo expuesto surgen claramente los grandes desafíos que plantea la compleja —pero al mismo tiempo angustiante y vital—, problemática ambiental: en cuanto atañe a la plenitud de la vida, la lucha frontal contra el riesgo o peligro a la incolumidad ambiental. Ello requiere de una nueva cultura jurídica. De un golpe de timón con la transfiguración de principios y estándares. Priorizando "respuestas vivas a los problemas de hoy".

En esta tarea, Lorenzetti, lúcidamente, afirma que: "El surgimiento de los problemas relativos al medio ambiente incide en la fase de las hipótesis, de planteamiento de los problemas jurídicos, suscitando un cambio profundo que avanza sobre el orden del Código, proponiendo uno distinto, sujeto a sus propias necesidades". "El derecho ambiental es descodificante, herético, mutante: se trata de problemas que convocan a todas las ciencias a una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. En el caso del Derecho, la invitación es

amplia, abarca lo público y privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, con la condición que se adopten nuevas características" (3).

Por ello es que no asusta que en relación al paradigma jurídico tradicional, el derecho ambiental se lo considere, reaccionario, de "carácter contestatario". Y que se afirme la idea que el derecho ambiental es una disciplina funcional o finalista, en el sentido de que no se encuentra como una rama jurídica neutra, pues trae una especie de *obligation de resultat* (obligación de resultado), según la expresión del notable jurista francés M. Prieur (4).

La Argentina padece de una serie de problemas ambientales de variada naturaleza, asociados a diversas actividades humanas que ponen en peligro el desarrollo sustentable del país. La teoría del desarrollo sustentable considera la posibilidad de llevar adelante un desarrollo económico preservando el ambiente, o sea, usando los recursos para satisfacer las necesidades de la población, sin comprometer esos recursos para las generaciones futuras.

Es importante comprender que la actividad humana es un subsistema que funciona dentro de un ecosistema más amplio pero más limitado, ya que la perturbación del mismo (sea por agotamiento o por contaminación) trastorna con el tiempo los sistemas sustentadores de la vida en que se basa la economía, provocando cambios ambientales duraderos y hasta irreversibles.

La recuperación de los ecosistemas degradados resulta enormemente costosa, lenta y en muchos casos imposible. De ahí que han adquirido gran importancia las políticas orientadas a prevenir efectos ecológicos y socioeconómicos considerables.

Sin embargo, la aplicación de medidas ambientales previsoras y preventivas suscita nuevas dificultades. Además de requerir los conocimientos para prever daños ambientales, y de la necesidad de reestructurar las instituciones para actuar en forma integrada cuando se trata de sustentar el desarrollo sostenible, la financiación está en primer lugar. Y no contamos en Argentina con una norma específica como existe en Estados Unidos denominada Ley de Superfondo (CERCLA), ni una agencia de protección ambiental como EPA, que aplique e impulse el sistema. Esta agencia está legitimada para ordenar la limpieza de un predio, por ejemplo.

En la actualidad, contamos con normas específicas, tanto provinciales o nacionales, que obligan a realizar evaluaciones de impacto ambiental respecto de toda actividad susceptible de causar un daño significativo al ambiente, como por ejemplo, construcción de diques, embalses, disposición final de residuos peligrosos, actividad minera y petrolera, entre otras. Todo ello como consecuencia de nuestro sistema federal de Estado.

(1) VÁZQUEZ GARCÍA, AQUILINO y SILVA REPPETTO, ROSSANA. <http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/445/presentacion.html>

(2) CAFFERATTA, NESTOR, palabras expuestas en el II Seminario Taller Internacional de Derecho Ambiental, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. www.idea.org.py

(3) LORENZETTI, RICARDO, *Las normas fundamentales del derecho privado*, Santa Fe, 1995.

(4) PRIEUR, MICHEL, *Droit de L'Environnement*, Paris, 1991.

Recién con la reforma constitucional de 1994, se incorporó el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades presentes satisfagan las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras.

2. REGULACIÓN NORMATIVA

Hecha la introducción a la temática que planteamos, corresponde ahora que analicemos el marco teórico constitucional en que se desenvuelve la problemática de la protección del medio ambiente en nuestro país.

Así las cosas, pasaremos a referirnos a los antecedentes que rondan la materia:

a). Antecedentes. Conferencias y tratados internacionales:

Como afirma Carlos Alfredo Botassi en su obra "Derecho Administrativo Ambiental", la cuestión ambiental no respeta ningún tipo de fronteras, debido a que los componentes del ecosistema, en especial agua y aire, no permanecen en un mismo sitio, sino que circulan permanentemente por el planeta.

Es así como el agua que potabiliza la Ciudad de Buenos Aires para consumo de sus habitantes, recibe los desechos químicos de las plantas industriales que se encuentran ubicadas en las márgenes de sus tributarios, Ríos Uruguay, Paraná, Iguazú y Paraguay.

La tala indiscriminada de la selva amazónica condenará a la humanidad a inundaciones y sequías crecientes, amén de privar al mundo de un generador de oxígeno de primer orden.

Tampoco resulta extraño que países con un elevado índice de industrialización, y por ende muy afectados por la contaminación, sean los líderes en el desarrollo del derecho ambiental, por ejemplo, Alemania, con los graves problemas que padece por la *lluvia ácida* que corroe y afecta a verdaderas joyas arquitectónicas de la humanidad, tales como las catedrales góticas.

Esta fatídica circunstancia ha posibilitado y dado nacimiento en dicho país, a los institutos más importantes de esta materia.

Surge claro entonces que, más allá de las medidas de orden interno que generan los Estados en el marco de su soberanía e *imperium*, en la actualidad la regulación del medio ambiente es una cuestión que debe ser coordinada entre varios países, para la defensa de la calidad del entorno del género humano.

Por ello, dividiremos este marco en tres planos distintos, el de las Relaciones Bilaterales, el de las Relaciones Multilaterales y finalmente el de los Organismos Internacionales.

• Relaciones bilaterales:

Argentina ha celebrado acuerdos con países limítrofes tendientes a proteger nuestro medio ambiente. Pueden citarse como ejemplos:

Declaración de Argentina y Bolivia: sobre cuencas hidrológicas del año 1971, en la cual se especifica que se evitará la contaminación y se preservarán los recursos ecológicos de las cuencas.

Declaración Conjunta de Argentina y Uruguay: también del año 1971, coincidiendo en que los ríos internacionales deben utilizarse evitando su contaminación.

Tratado del Río de la Plata: del año 1973 firmado entre Argentina y Uruguay, en el mismo aparecen varias disposiciones por las cuales las partes suscribientes se obligan a mantener libre de contaminación ese importantísimo curso de agua.

Estatuto del Río Uruguay firmado entre Argentina y Uruguay: del año 1975, las partes se obligan a proteger su calidad y ecosistema.

• Relaciones multilaterales:

Nuestro país ha suscripto o adherido una cantidad de documentos por los cuales se propende a la conservación del medio ambiente.

En el año 1969 firmó el "*Tratado de la Cuenca del Plata*", firmado en la Ciudad de Brasilia, por el cual se dispone la realización de estudios, programas y obras para la preservación y fomento de la vida animal o vegetal de la región.

Idénticas motivaciones de preservación de nuestro ecosistema, se verifica en el contenido del *Tratado Antártico* del año 1959, de *Ensayos Nucleares* de 1963 y de *Cooperación del Amazonas* de 1978.

• Organismos internacionales:

En el ámbito de las Naciones Unidas, la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO) se ocupa desde su creación, en el año 1945, de los problemas de la erosión de suelos, de la extinción de especies animales, y de los planes de forestación.

Sin embargo, en la década del 70, y por iniciativa de la ONU, se lleva a cabo un importante evento internacional que sienta las bases del moderno derecho ambiental.

La Conferencia de Estocolmo del año 1972 creó el "Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente" (PNUMA), con sede en Kenia, y con una representación regional para América Latina con sede en la Ciudad de México.

Esta conferencia internacional, de suma importancia dado que dio origen, en el plano internacional, al derecho ambiental y a la organización de una política preservacionista en materia de recursos naturales, contó con la notable intervención de un insigne jurista argentino, que fuera el único experto latinoamericano a nivel internacional en dicha reunión que intervino en la redacción del documento final. Nos referimos al Dr. Guillermo Jorge Cano.

Dicha conferencia, llevada a cabo en esa ciudad escandinava entre el 5 y 16 de junio de ese año, formuló una declaración que, pese a los años y lamentablemente, hoy en día no ha perdido actualidad en absoluto.

La misma se compone de un "Preámbulo", donde se establece que el objeto de la reunión es forjar criterios y principios comunes que ofrezcan al mundo inspiración y guía para preservar el medio ambiente humano.

Luego formula una "Declaración", donde se destaca que los dos aspectos del medio humano, el artificial y el natural, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluyendo dentro de esta última categoría *el derecho a la vida misma*.

También enuncia una serie de "Principios", los cuales constituyen la parte verdaderamente dispositiva de la "Declaración", las cuales podemos resumir de la siguiente manera:

Contaminación Ambiental: Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas y a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas. Debe apoyarse la lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación.

Desarrollo y Medio Ambiente: Al planificarse el desarrollo económico, debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluida la flora y fauna silvestres.

Derechos y Obligaciones de los Hombres: Todo ser humano posee el derecho fundamental a vivir en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar. Al mismo tiempo tiene la obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras, debiendo los gobiernos planificar el uso de los recursos ambientales de la tierra, agua, aire, suelo, flora y fauna, evitando su futuro agotamiento.

Deberes de los Gobiernos: Los Estados deberán tomar todas las medidas necesarias para impedir la contaminación. Deben destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio y adoptarse enfoques integrados y coordinados de la planificación del desarrollo para que no se contradiga con la calidad del entorno.

Solidaridad y Cooperación Internacional: Los Estados tienen la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control, no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de su jurisdicción nacional. Los Estados deben cooperar para desa-

rollar el derecho internacional en lo referente a la debida indemnización a las víctimas de la contaminación.

La Declaración fue suscripta por 113 países, entre ellos, la República Argentina.

En el ámbito regional también podemos citar como antecedente el conocido *Pacto de San José de Costa Rica*, o *Convención Americana sobre Derechos Humanos*, la cual se encuentra incorporada a nuestro derecho positivo a través de la sanción de la ley 23.054. Establece en sus arts. 2º, 4º y 5º el deber de los Estados signatarios de asegurar el derecho a la vida y a la integridad física, psíquica y moral de sus habitantes.

Al momento de la sanción de la ley, y por efecto de los arts. 27 y 31 de la Constitución Nacional, tales prevenciones integran nuestro ordenamiento jurídico.

Sin perjuicio de ello, a partir de la reforma constitucional de 1994, y por el expreso mandato constitucional contenido en el art. 75 inciso 22 de nuestra Ley Fundamental, dicha Convención tiene jerarquía constitucional.

En la concreta cuestión que estamos tratando, debemos puntualizar que mediante Resolución n° 19 de la OEA del año 1987, el Comité Jurídico Interamericano recomendó la creación de un "Sistema Interamericano de Conservación de la Naturaleza", estando a cargo de la Secretaría General de la Organización la realización de los estudios necesarios para proyectar la redacción de un convenio internacional.

El espíritu y en muchos casos la letra de todos estos antecedentes, hoy forman parte de nuestro derecho público interno a través de su incorporación al texto de nuestra Constitución Nacional.

b) Antecedentes provinciales

Yendo ya a nuestro derecho público interno, algunas Constituciones provinciales, han legislado sobre el medio ambiente en sus territorios, incluyendo regulaciones en su texto constitucional local.

Es así como en el año 1986, dan a luz dos constituciones provinciales que obligan al Estado Provincial a establecer políticas activas de promoción y defensa del medio ambiente en las mismas, garantizando de esta manera la calidad de vida de sus habitantes:

- *La Rioja:*

Así la Constitución de la Provincia de La Rioja, en su art. 66, establece lo siguiente:

"...El Estado promoverá la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente en el territorio provincial para lograr una óptima calidad de vida..."

• *San Juan:*

Por otra parte, la Constitución de la Provincia de San Juan, dispone en su art. 58:

"... Corresponde al Estado Provincial, por sí o mediante apelación a iniciativas populares, prevenir y controlar la contaminación y sus efectos, y las formas perjudiciales de erosión, ordenar el espacio territorial de forma tal que resulten paisajes biológicamente equilibrados..."

Sin perjuicio de que ambos textos establecen obligaciones muy precisas en cabeza del Estado Provincial, sendos cánones contienen también motivaciones concretas que han llevado al constituyente provincial a regular dicha materia, tal el aseguramiento de la "calidad de vida" de los habitantes, como así también garantizar un "paisaje biológicamente equilibrado".

• *Provincia de Buenos Aires:*

Con posterioridad, la Provincia de Buenos Aires, luego de la reforma constitucional local del año 1994, ha legislado de una manera exhaustiva en la materia, incorporando una "Cláusula Ecológica" en su texto, concretamente en el art. 28, el cual establece:

"... Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano, y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio, incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambiental adecuada. En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables, del territorio de la Provincia, planificar el aprovechamiento racional de los mismos, controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema, promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo, prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radioactivos, y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales. Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y de la fauna. Toda persona física o jurídica cuya acción pueda degradar el ambiente, está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo..."

Como podemos apreciar, la norma constitucional bonaerense resulta sumamente amplia y completa, siguiendo los lineamientos de la Constitución Nacional en la materia.

La norma constitucional provincial contiene una enorme riqueza, ya que alude a una gran variedad de supuestos todos ellos, en mayor o menor medi-

da, debidamente reglamentados por la Legislatura Provincial a través de la sanción de la Ley de Medio Ambiente 11.723.

1) Se reconoce a todos los habitantes de la Provincia un derecho a gozar de un medio ambiente sano, lo cual implica que las actividades económicas o de otra índole que se lleven a cabo en su territorio, no deben ser agresivas para la salud de sus habitantes.

2) Ese reconocimiento no se agota en la persona física actual, sino que se proyecta hacia adelante, a las generaciones futuras. Esto implica el deber ineludible del Estado de planificar políticas de cuidado del medio ambiente a largo plazo.

3) Establece el dominio público provincial sobre el ambiente y los recursos naturales, ya sea que éstos se encuentren en el suelo, subsuelo, agua o aire.

4) Establece asimismo la prohibición del ingreso de cualquier residuo tóxico o radioactivo. Entendemos que esta prohibición es operativa *per se* y que no necesita reglamentación alguna para su funcionamiento.

5) Reconoce una legitimación activa amplia para solicitar y recibir información adecuada y para participar de la defensa del medio ambiente.

6) Establece la obligación del Estado Provincial de asegurar políticas de conservación y recuperación de la calidad del suelo, agua, aire, flora y fauna. Si bien muchas veces los recursos naturales, más en una Nación con nuestra potencialidad, parecen inagotables, el Estado no puede rehuir su obligación de asegurar un desarrollo de tipo sustentable. Esta cuestión también tiene mucho que ver con un adecuado y razonable ejercicio del poder de policía ambiental.

7) Impone la obligación de toda persona física o jurídica que actúe en territorio provincial, de evitar realizar acciones que puedan en acto o en potencia degradar el medio ambiente. Entendemos que esta prohibición tiene varias facetas. Si una empresa, con su actividad, contamina el curso de agua de una ciudad, deberá prioritariamente restituir el nivel de calidad del río o arroyo, y después deberá compensar pecuniariamente a sus habitantes por la contaminación producida.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, había resuelto que "cuando el daño deriva del riesgo de la cosa, el art. 1113 del Cód. Civil, no crea una presunción de culpa, ni invierte la carga de la prueba. Ese riesgo da nacimiento a la responsabilidad del dueño o del guardián de la cosa, con total independencia del elemento subjetivo de la culpa, que no constituye ningún presupuesto del deber de resarcir. Acaecido el daño, derivado del riesgo o vicio, el dueño o guardián, no se libera demostrando que de su parte no hubo culpa, porque ello no interesa a este régimen de responsabilidad. Se es responsable por existir la creación del riesgo, que abastece el deber de reparar el daño" (Ac. 32.896, "Castiglioni", A y S, 1986-III-263).

c) Otros antecedentes constitucionales

En el derecho comparado, además de aquellas constituciones que enuncian el derecho a la vida o a la salud poniendo a cargo del Estado el deber de su protección, existen otras que abordaron implícita y explícitamente la cuestión ambiental.

c.1) Constituciones de la posguerra (5)

- *Constitución Española de la II República de 1931:*

Una de las primeras constituciones en tratar dicha temática fue la de España de 1931, que en su art. 45.2 establece que el Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico. Alguna doctrina sugiere que este precepto pudo inspirar la redacción del art. 9.2 de la Constitución Italiana de 1947.

Como derivación del derecho constitucional a "disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona" (art. 45 de la Constitución de 1978), el Reglamento de la Ley de Protección del Ambiente, faculta a cualquier persona a solicitar al Gobierno, una declaración de zona de atmósfera contaminada.

- *Constitución Italiana de 1947:*

Asigna a la República la "tutela del paisaje y del patrimonio histórico y artístico de la Nación". En su art. 9.2., lo estableció como principio fundamental de la República.

Esta norma fue concebida inicialmente para la mera conservación de las bellezas naturales junto con el art. 32 —tutela a la salud—.

- *La Grundgesetz de Bonn de 1949:*

Se refería a materia ambiental sólo en relación a la distribución de competencia entre el Estado y los Länder.

El art. 74 se ocupa de la legislación concurrente, donde hay algunas que se relacionan directa o indirectamente con el medio ambiente: a) la legislación en materia económica, b) protección de los árboles y plantas contra las enfermedades y parásitos, la protección de los animales y la eliminación de desechos y lucha contra la contaminación atmosférica y los ruidos.

- *Constitución Checoslovaca de 1960:*

Establece en su art. 15: "El Estado es responsable del mejoramiento y la protección general de la naturaleza".

- *Constitución de la República Democrática de Alemania de 1968:*

También en su art. 15 establece "A fin de promover el bienestar de los ciudadanos, el Estado y la Sociedad garantizarán la protección de la naturaleza".

- *Constitución Francesa:*

En Francia, la ley 629 del año 1976, sobre protección de la Naturaleza, otorgó legitimación a las Asociaciones y Grupos Ecologistas, para accionar contra los agresores del entorno, en ejercicio del derecho colectivo a vivir en un medio apto.

c.2) Las constituciones mediterráneas de la década de los 70

- *Constitución Griega de 1975:*

Establece en su art. 24: "La protección del ambiente natural y cultural constituye un deber del Estado".

- *Constitución Portuguesa de 1976:*

Establece en su art. 60: "Incumbe al Estado prevenir y controlar la contaminación y las formas perjudiciales de erosión, ordenar el espacio territorial, garantizando paisajes biológicamente equilibrados".

Como podemos apreciar, ha sido una constante la preocupación de varios estados de insertar en su texto constitucional, cláusulas que aseguren un medio ambiente equilibrado en sus territorios, estableciendo pautas preservacionistas en materia de los diversos tipos de contaminación que pueden afectar al medio ambiente.

Pero a nuestro criterio, es la Constitución de España del año 1978 la que ha influido decididamente en nuestros constituyentes al momento de redactar el art. 41 de nuestra Carta Magna.

Dispone el art. 45 de la Constitución Española:

"... Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado...".

d) El art. 41 de la Constitución Nacional:

La reforma de la Constitución de agosto de 1994, incorporó al texto constitucional la llamada *cláusula del medio ambiente o ecológica*, en el art. 41, el cual ha quedado redactado de la siguiente forma:

(5) GUEVARA PALACIOS, AUGUSTO, "Algunos aspectos del medio ambiente en el Derecho Constitucional Comparado", LA LEY, del 26 de agosto de 2004.

"... Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que con tengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y los radioactivos..."

Como puede apreciarse, la norma constitucional alude a diversas cuestiones del derecho ambiental, las cuales pueden resumirse de la siguiente manera:

a) Otorga derecho a todos los habitantes para que no se agreda su salud, asegurando el mantenimiento de un "ambiente sano". El desarrollo de las personas debe conjugarse no sólo en el plano económico, sino también afectivo y cultural. El ambiente equilibrado se refiere al equilibrio ecológico, esto es, la necesaria armonía que debe existir entre la naturaleza y la actividad humana.

b) El derecho de toda persona de ver satisfechas sus necesidades presentes, no puede comprometer el derecho de las generaciones futuras. He aquí incorporado a nuestro texto constitucional el concepto de *solidaridad colectiva* o *inter-generacional* ya desarrollado en la constitución española.

c) El derecho de todos, también configura un deber de todos, o como diría Duguit, nos encontramos frente ante una *obligación pasivamente universal* de la sociedad en su conjunto, de no agredir al medio ambiente. Consecuentemente, quien por acción u omisión esté en condiciones de injuriar el medio en que se desenvuelve, tiene el deber de acudir a la más moderna tecnología para amortiguar el impacto ambiental de su conducta.

d) El daño ambiental no debe acarrear solamente el deber de indemnizar a las víctimas, sino que genera una obligación prioritaria, *la de restaurar las consecuencias dañinas para el ambiente*. Si una industria contamina el curso de agua de una comunidad, no solamente deberá indemnizar a los habitantes de la misma, sino que en primer lugar deberá ser condenada a restituir el nivel de calidad del arroyo o río.

e) La protección de los derechos ambientales es un deber del Estado Nacional, como así también de los Estados Provinciales y aún de las Municipalidades, debiendo los mismos establecer las medidas de poder de policía adecuadas a ese fin.

f) La información y la educación ambiental también es una obligación ineludible del Estado, el cual debería incluir esta temática dentro de los planes obligatorios de educación.

g) La prohibición del ingreso al territorio nacional de residuos peligrosos y radiactivos, correlaciona con lo establecido por el decreto del PEN 181/92 y luego por la ley 24.051. La fórmula legal es más amplia que el texto constitucional, ya que no se limita a prohibir la importación de desechos considerados peligrosos, sino que impide el ingreso de todo tipo de residuos o sustancias provenientes de otros países (art. 3º de la ley). Por eso pensamos que, en el marco de la Constitución Nacional y del canon legal premencionado, debería limitarse seriamente la producción de algunas sustancias químicas utilizadas muy intensivamente en la actividad agrícola de nuestro país. Nos referimos concretamente a los insecticidas fosforados, tipo *Paration* o *Parapest* que son sumamente efectivos en la eliminación de plagas agrícolas, pero sumamente dañinos para el medio ambiente. No debemos olvidar que estos dos plaguicidas fueron utilizados con mucho éxito como armas de guerra por los Estados Unidos en Vietnam y en la primera guerra del Golfo. Esta política ambiental se inserta en lo establecido en el Convenio Internacional de Control de Movimiento de Desechos Peligrosos, suscripto en la Ciudad de Basilea en 1986, aprobado por nuestro país por ley 23.922. Este tratado reconoce a todo Estado "... el derecho soberano de prohibir la entrada o la eliminación de desechos peligrosos y de otros desechos ajenos en su territorio ...". Finalmente, entendemos que la prohibición de residuos radioactivos en nuestro territorio nacional, es un mandato constitucional operativo *per se* y que por ello no necesita de reglamentación para su inmediata puesta en vigencia.

h) Si no se definen claramente los roles y no se fortalecen institucionalmente a aquellos que tienen que cumplirlos, es muy difícil lograr los objetivos del artículo 41 que es el marco de la legislación ambiental. La Constitución Nacional concede a la nación competencia para fijar normas sobre presupuestos mínimos y deja a decisión de las provincias las competencias para complementarlos sin alterar las jurisdicciones locales. Es decir que es una distribución cuantitativa. Hay un presupuesto mínimo que es de la nación. A esto se agrega un máximo optativo que queda para determinar por las provincias (6).

d) Las primeras leyes en el derecho comparado

En Estados Unidos el Congreso dictó la ley nacional de política ambiental y crea la autoridad de aplicación, E.P.A. Luego dictó las pautas básicas para los distintos medios. Hubo largos conflictos entre autoridades de aplicación y de política.

En Australia se implementó un acuerdo intergubernamental en 1991, que fija normas de procedimiento. Se establecen los roles institucionales y las pautas para solucionar o evitar las superposiciones.

En México la constitución deja todo en manos de la nación, la Federación Mexicana. Esto llevó a un aislamiento legislativo que condujo a que la nación

(6) Exposición del Dr. SABSAY durante la *Jornada sobre Residuos Urbanos*, 24/6/1998.

se deshiciere de ciertas potestades delegadas en los estados o municipios. La solución necesita de un Gobierno Superior que observe la globalidad ambiental y solucione los problemas jurisdiccionales, pero debe compadecerse con la regla de la autoridad local que es donde se produce el problema ambiental (7).

Las más antiguas se concentran en la prevención de riesgos de higiene ambiental y salud pública.

La primera legislación específica sobre el medio ambiente se produce en las principales áreas tradicionales de la legislación ambiental estadounidense. Así, son conocidas las provisiones de las importantes leyes nacionales *Environmental Policy Act* de 1969, *Clean Air Amendments* de 1970, *Federal Pollution Control Act Amendments* de 1972, *Noise Control Act* de 1979, *Solid Waste Disposal Act* de 1976 (8).

La etapa siguiente se orienta al control de usos de recursos y produce la legislación contemporánea sobre reservas de dominio o uso de la tierra, el subsuelo, el agua y el aire. Tal dirección conduce naturalmente al asunto del manejo de los recursos naturales.

En un momento, como lo señala Ramírez, se consideró que la cuestión de los recursos naturales se debía desarrollar en otra rama de la Jurisprudencia: el Derecho de los Recursos Naturales con muchas coincidencias, no obstante, con el Derecho Ambiental (9).

e) Leyes nacionales y/o provinciales

Leyes Nacionales

En materia ambiental la ley de leyes es la ley general del ambiente 25.675 —sancionada el 06/11/2002 y promulgada parcialmente por decreto 2413, el 27/11/2002—.

Incluye en su contenido:

1. Principios: Derecho al ambiente. Prohibición de contaminar. Estándares de protección. Planificación ambiental. Desarrollo sustentable. Principio de prevención. Quien contamina paga. Libre acceso a la información ambiental. Principio de aplicación de la mejor técnica disponible. Intangibilidad del ambiente. Principio de colaboración empresaria.

2. Estrategias: EIA. Sistema de auditorías ambientales. Planes de contingencia y de prevención de grandes accidentes. Tributo ambiental. Eco-Etiqueta o certificado de aptitud ambiental. Instrumentos financieros para la

(7) SABSAY, op.cit.

(8) FRANZA, JORGE ATILO, *Tratado de Derecho Ambiental*, Buenos Aires, 2005.

(9) RAMÍREZ REBOLLEDO, GUILLERMO, *Legislación Ambiental de los Países del convenio Andrés Bello*, Bogotá, 1990, ps. 7-10.

protección del medio ambiente. Control integrado de la contaminación. Control de la contaminación desde su fuente. Aplicación progresiva de normas.

3. Materias: a) Derecho a la información ambiental. Garantías de acceso a la información. Habeas data ambiental. Creación de sistemas que lo permitan. Obligación de informar de aquél que conoce la posibilidad de daño o el daño ocasionado. Participación ciudadana democrática. Procedimiento de audiencias públicas; b) Educación e investigación ambiental. Difusión, fomento y garantías de acceso; c) Procedimiento ambiental. Legitimación. Audiencias públicas. Acción de amparo. Otras acciones de defensa del ambiente. d) Autoridad de aplicación en materia ambiental. Creación. Atribuciones y funciones. Coordinación con las otras autoridades con incumbencias en la materia. Competencia. Policía ambiental, control y vigilancia. Medidas de seguridad; e) Jurisdicción y competencia; f) Control de actividades peligrosas; g) Residuos peligrosos y radiactivos. Prohibiciones, tratamiento y disposición final; h) Residuos en general; i) Salud humana; j) Utilización racional de recursos naturales; k) Protección particular de los recursos. Agua: calidad mínima requerida para el agua potable y para sus otros usos. Control de efluentes domiciliarios e industriales. Condiciones mínimas requeridas para el servicio de agua potable y saneamiento. Aire: límites de contaminación atmosférica. Calidad mínima requerida del aire. Límites sonoros admisibles. Contemplación de las distintas fuentes de emisión Suelo: Régimen para su ordenamiento (territorial y urbano) y normas mínimas para su cuidado. Fauna y Flora (bosques, espacios verdes): Protección de los recursos animales y vegetales en general y en particular de aquellos en peligro de extinción. Conservación de hábitat naturales, bosques y espacios verdes. Instrumentación. Reglas para la prevención de incendios. preservación del patrimonio natural y cultural; m) Protección de la biodiversidad; n) Sanciones administrativas ante el incumplimiento; o) Responsabilidad en materia ambiental. Obligación de recomponer. Daño ambiental. Responsabilidad civil. Responsabilidad penal. Formas de repararlo: indemnización y recomposición (modificación del Código Civil). Herramientas jurídicas que permitan afrontarlo. El seguro ambiental. Los fondos especiales de reparación; p) Régimen de sanciones penales.

Cafferatta estipula que los objetivos de la ley, responden a los fines de lograr "una gestión", tanto privada como pública, "sustentable y adecuada del ambiente"; como asimismo "la preservación y protección de la diversidad biológica"; y en términos generales, "la implementación del desarrollo sustentable".

Coinciden con las recomendaciones contenidas en el documento preparado por la Unión internacional de conservación de la naturaleza y de los recursos naturales (UICN), con la asesoría, cooperación y apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) (10).

(10) Publicado por la revista "A y RN", FARN, Editorial La Ley, enero-marzo 1985, vol. II, N° 1- "Estrategia Mundial para la Conservación - La conservación de los recursos vivos para el logro del desarrollo sostenido".

En dicho documento, se afirma que además de la integración de la conservación y el desarrollo una gestión sana requiere una legislación, una organización, una capacitación y una información eficaces. Destacándose como uno de los defectos de organización más frecuentes la falta de coordinación entre los organismos públicos. Además que la legislación específica e integral, contenga requerimientos de evaluación de impacto ambiental y otros mecanismos de participación de los ciudadanos en el proceso político, así como el suministro de una información suficiente para que dicha participación sea efectiva, dentro de la cual se inscribe la educación ambiental (11).

Leyes provinciales

La Ley 11.723 de Protección Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, ha modificado sustancialmente el ámbito judicial de defensa del entorno. En su art. 23, referido al control de impacto ambiental, establece que si la Administración omitiera actuar frente a un proyecto de obra o de actividad, iniciado irregularmente, el mismo "podrá ser suspendido por cualquier autoridad judicial con competencia territorial". Queda así consagrada una acción judicial especial, tendiente a paralizar una obra o una actividad, por mandato judicial, en defensa del ambiente. Aunque la ley no lo especifica, debe entenderse que cualquier habitante está legitimado para solicitar la intervención del juez, y el trámite por su naturaleza, debería ser de carácter sumarísimo (art. 496 del CPCC de Bs. As.).

El capítulo IV de la Ley, rotulado "de la defensa jurisdiccional", contempla la posibilidad de accionar contra el estado (arts. 34 y 35), o contra particulares. En el primer supuesto, por "cualquier habitante", en sede administrativa, si no obtuviera resultado positivo, el "afectado, el defensor del pueblo, y/o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente", quedarán habilitados para acudir ante la justicia con competencia en lo Contencioso Administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada.

El texto legal merece algunas consideraciones. Cuando se alude a la actuación en sede administrativa, se legitima a "cualquier habitante", pero cuando se habilita la vía judicial, se alude al "afectado", es decir, a quien pueda acreditar un agravio personal y directo. De esta manera, la legitimación ante la Administración resulta más amplia que la posibilidad de acudir ante el Juez en lo Contencioso Administrativo.

En los casos en que el daño o la situación de peligro sea consecuencia de acciones u omisiones de particulares, el afectado, el defensor del pueblo, y/o las asociaciones que propendan a la protección del medio ambiente, podrán acudir directamente ante los tribunales ordinarios competentes, ejerciendo: a) acción de protección, a los fines de prevención de los efectos degradantes que pudieran producirse; b) acción de reparación, tendiente a restaurar o

recomponer el ambiente, y/o los recursos naturales, ubicados en territorio provincial, que hubieran sufrido daños como consecuencia de la intervención del hombre. La acción ambiental contra particulares, admite entonces dos vertientes: preventiva y reparadora. También se reserva la legitimación para el afectado, más allá de la posibilidad de que accionen el defensor del pueblo y las asociaciones ambientalistas. En ambos casos, el trámite será el correspondiente al juicio sumarísimo (art. 37).

3. JURISPRUDENCIA NACIONAL Y/O PROVINCIAL

a) Casos relevantes anteriores a la reforma constitucional:

1º) "Quesada, Ricardo" (La Ley, 1980-D, 130)

Mediante la vía del amparo, el accionante cuestionó una poda de árboles que se estaba efectuando sobre la Plaza Grand Bourg, de la Capital Federal. El juez de Primera Instancia, Juan Carlos Smith, había admitido el amparo, argumentando que: "frente a un bien del dominio público (como lo es una plaza), todos los habitantes poseen un 'interés legítimo' en su condición de usuario, por los efectos previstos en el art. 2341 del Cód. Civil", "cuando los actos de la Administración Pública, puedan exceder el marco de una amenaza a la intangibilidad o conservación de esta especie de bienes, cualquier ciudadano está facultado para ejercer las acciones implicadas en la soberanía del pueblo, titular del dominio público".

Con sustento en lo previsto en el art. 33 de la Constitución Nacional (el derecho ambiental aún no había sido introducido por la reforma del año 1994), el sentenciante hizo lugar al amparo incoado, con el fin de evitar la tala de árboles, y la modificación del entorno forestal de la Plaza, que "perdería su aspecto ambiental característico; y con ello, desaparecería una imagen ya tradicional, de profunda relevancia histórica, que el sentimiento ciudadano —en tanto expresión innegable del querer del titular del dominio público—, exige respetar".

La Cámara Nacional Civil, Sala D, rechazó su pretensión por entender que esa discusión era una "cuestión política", ajena al contralor jurisdiccional.

2º) "Christou c. Municipalidad de tres de Febrero" (ED, 118-183) (Fallos: 308:155) (1986)

Varios vecinos demandaron amparo contra la Municipalidad de Tres de Febrero, pidiendo la anulación de una Ordenanza que fijaba un área del Partido como zona industrial, convalidando la actividad de una fábrica allí instalada, y cuestionada como contaminante. Sostuvieron que ese acto estaba en pugna con diversas normas de procedimiento, y afectaba sus derechos a vivir una vida sana, sin las molestias de ruidos y olores que afectaban la salud. En las dos instancias de grado, el pedido de amparo fue rechazado, por entenderse que existían otras vías ordinarias para debatir el punto litigioso. La causa llegó a conocimiento de la Corte Nacional, que dio razón a los accionantes.

(11) BELLORIO CLABOT, DINO, *Tratado de Derecho Ambiental*, Buenos Aires, 1997, p. 629.

68

Si bien no se abordó en ningún momento el tema de la legitimación, la sentencia del Superior tribunal, contiene párrafos de interés. La Corte se pronunció el 20/02/1986, declarando que en la especie, se advertían restricción de "derechos esenciales de las personas", y dejó sin efecto la sentencia de la Cámara de Apelaciones de San Martín, y mandó a fallar nuevamente.

3º) "Almada c. Copetro", "Irazú c. Copetro", y "Klaus c. Copetro", sentencia conjunta del 22/12/1992

La Sala 3ª, Civil y Comercial de La Plata, en tres procesos por daños y perjuicios contra la misma planta fabril, declaró que el interés colectivo o difuso (el que posee toda la comunidad para contar con un medio ambiente sano), no es otra cosa que la sumatoria de cada fragmento del interés individual amparado por la ley. Como derivación de este criterio, entendió que la sentencia que condenó a terminar con la conducta degradante del entorno, "ha de tener efectos *erga omnes*", lo contrario "llevaría a un desprestigio mayúsculo a la magistratura: el del un juez que ante la evidencia de un daño a la salubridad de la población o de un sector de ella, limite su pronunciamiento a la tutela de los intereses individuales de los sujetos que demandaran, sin amparar el interés supraindividual de la comunidad que aquellos integran y sin lo cual aquellos intereses y el orden público permanecerían lastimados".

b) Casos posteriores a la reforma constitucional:

1º) "Schroder, Juan c. Estado Nacional"

Se trata del primer caso en el cual un Tribunal de Justicia hizo aplicación del reformado artículo 43 de la Constitución Nacional. El actor, invocó su condición de "vecino" del Partido de Tres de Febrero, para solicitar la nulidad de la Resolución de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, que llamó a licitación para contratar la construcción y operatoria de plantas de residuos peligrosos, sin un previo estudio de impacto ambiental. Entre otras defensas, la demandada adujo ausencia de legitimación en el accionante, sosteniendo que no existe en nuestro derecho positivo, la protección de los intereses legítimos, y denunció la existencia de otras vías para debatir la cuestión de fondo.

Tanto el Juez de Primera Instancia, como la Sala III de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, aceptaron la legitimación del "vecino". El Tribunal aclaró, que la defensa de falta de legitimación pudo sustentarse antes de la reforma constitucional de 1994, pero, actualmente, el nuevo art. 41 de la Carta Magna, consagró el derecho a un ambiente sano, y correlativamente, "estableció una protección procesal especial para ese nuevo derecho, mediante la acción de amparo. Según el art. 43 de la C. N., cuando se trata de la protección de los derechos relativos al ambiente, la acción podrá ser interpuesta por el afectado".

Esta condición se encuentra debidamente cumplida con el interés personal y directo que, en el caso, ostenta el actor. Máxime, si se tiene en cuenta, que

dedujo una pretensión exclusivamente anulatoria, con lo cual, no pretende, además, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, y su eventual restablecimiento". En cuanto a la existencia de otras vías administrativas que desplazarían el amparo judicial, la Cámara entendió que "el art. 43 de la Constitución Nacional, para supuestos como los de autos, en que podría producirse la lesión con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, implica la derogación orgánica de ese requisito, por resultar incompatible con sus disposiciones. En efecto, su texto establece que procederá la acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio más idóneo. La obligada aplicación directa de esa norma constitucional para decidir el caso, torna improcedente el planteo efectuado". De esta manera, con sustento en el nuevo orden constitucional, la sentencia aludida (que fue consentida por las partes), significó la ratificación judicial de la facultad procesal de cualquier ciudadano para acudir ante los jueces, solicitando amparo frente a decisiones administrativas que, con ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, pueden afectar al medio ambiente.

2º) "Rusconi, Oscar c. Municipalidad de La Plata", del 4 de julio de 1995, en la causa B-55.392

La Corte bonaerense ha dado un vuelco trascendente en la materia, al admitir precisamente, la legitimación del titular de un interés legítimo, para accionar en el ámbito Contencioso Administrativo. Se trata de la sentencia dictada en la cual se reconoce que, frente a la violación de normas urbanísticas, el "vecino" posee acción contencioso administrativa para restituir la legalidad, pidiendo al Tribunal que anule los actos administrativos de autorización que lo agravian.

La Suprema Corte entendió que, en rigor, el Código de Varela, alude a "derechos de carácter administrativo", y no, a "derechos subjetivos", citando en apoyo de su opinión, los "principios liminares del Estado de Derecho, esto es, el de legalidad administrativa, y el de acceso a la justicia". De esta manera, se rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la Municipalidad demandada, considerando que si bien el vecino es un tercero respecto de la relación jurídica, existente entre aquella y el propietario de una estación de servicio, que obtuvo una autorización irregular para proceder a su ampliación, está habilitado para exigir el cumplimiento de las reglamentaciones dictadas en defensa de la calidad de vida de la población.

Cualquiera sea el tipo de causa y el fuero interviniente, aquellas sentencias que determinen que una actividad es contaminante, y que pone en peligro la salud pública, hará cosa juzgada respecto de esta circunstancia, no sólo en relación al caso concreto, sino respecto de cualquier otro pleito donde ese hecho aparezca en discusión, salvo que varíen las circunstancias fácticas.

4. PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL DEL ENTORNO

El art. 19 de la Constitución Nacional excluye de la autoridad de los magistrados el juzgamiento de las conductas que "no ofenden el orden y la moral pública, ni perjudiquen a terceros"; en sentido contrario, reconoce la intervención judicial cuando uno o más sujetos "perjudiquen a terceros", o aún peor, a

la comunidad en su conjunto, objetivo de nuestra organización nacional, conforme el Preámbulo de nuestra Carta Magna. Consecuentemente con ello, debe dotarse a los habitantes de acciones administrativas y judiciales que les permitan obtener la protección de sus derechos a una mejor calidad de vida.

El art. 1109 y conchs. del Cód. Civil, y la noción de responsabilidad objetiva, han facilitado la labor de los jueces al condenar la reparación de los perjuicios sufridos, y en contadas y plausibles ocasiones, el cese de la actividad nefasta con apoyo en el art. 2618 del citado plexo legal.

El derecho ambiental no se ocupa solamente de restaurar lo dañado y aspira fundamentalmente a prevenir el ilícito ecológico, ya que ha elevado la calidad del entorno a la categoría de valor colectivo, parte del "bien común".

La idea de bien común comprende la de bienestar general del Preámbulo y la prosperidad del país del art. 75, inc. 18 de la Constitución Nacional. Es en este sentido que se pregona el desarrollo de nuevos derechos subjetivos que la población antes no tenía y que ahora tiene, por lo menos teóricamente, contra los comerciantes, contaminantes, ladrones y contra la burocracia estatal.

El poder de policía ambiental, puede ejercerse oficiosamente mediante la actividad de los cuerpos de inspectores de los órganos con competencia en la materia, o como respuesta a un estímulo de un particular.

En algunas ocasiones, el agravio al entorno realizado por los particulares, cuenta con actos administrativos habilitantes o de autorización. En esos casos, la decisión estatal, debe cuestionarse ante el Juez, con competencia en lo Contencioso Administrativo, debido a la interpretación tradicional de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Para acceder a esa instancia, el actor debe contar con un derecho subjetivo vulnerado por el acto en cuestión. No es suficiente la invocación de un interés legítimo, ni tampoco, enarbolarse simples intereses afectados. Desde luego, no se admite en ningún caso, la legitimación derivada de acciones populares, ni individuales, ni grupales. En ese marco, el Superior Tribunal, ha admitido que "la extraordinaria acumulación de la población en el limitado ámbito de las urbes modernas, ha impuesto la necesidad de limitar múltiples actividades que agravan la atmósfera en que viven los ciudadanos. La norma establecida en la relación posible entre la magnitud de la edificación y la población, es un medio incuestionable para paliar graves daños en la salud del ciudadano (Causa B-46.950, "Delco", 4/3/1980). Sin embargo, ha negado legitimación al colindante perjudicado por una obra autorizada en violación al Código de Edificación Municipal, por entender que el vecino "sólo está afectado en un interés legítimo" (Causa B-47.262, "Duro de Bagrat", 3/4/1979).

5. DESARROLLO SUSTENTABLE

Algunos arguyen que existe un Derecho Humano Internacional al medio ambiente. Siguiendo esta línea de pensamiento, la Declaración de Estocolmo

bajo el marco de la Convención sobre el Ambiente Humano de 1972 señala en su preámbulo que *el medio ambiente es esencial para... el disfrute de los derechos humanos básicos*. La visualización del desarrollo sustentable como un derecho humano es relativamente reciente. Aunque podría decirse que en los documentos generales sobre derechos humanos ya se consagraba de manera implícita tal aspecto, no fue hasta 1986 que en el marco de las Naciones Unidas se aprobó la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (12).

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1986 la "Declaración sobre el Derecho al Desarrollo", en la que se señala que *el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable de todo ser humano y de todos los pueblos a ejercer soberanía plena y completa sobre todos sus recursos y riquezas naturales en procura de su desarrollo económico, social y cultural* (13).

Con posterioridad a tal Declaración se ha reiterado en diversos foros e instrumentos internacionales la concepción del desarrollo como derecho humano. Es un derecho humano garantizado en el derecho internacional.

Consideramos vital tal reconocimiento del desarrollo como un derecho humano. Lo contrario, es decir, concebir el desarrollo como un proceso *primordialmente económico* no relacionado con los derechos fundamentales de las personas podría llevar a un *desarrollo no sustentable*.

El derecho al desarrollo sustentable y los derechos humanos tienen una relación muy estrecha entre sí. Un desarrollo sin respeto a los derechos humanos no será en definitiva sustentable, mientras que una situación de pleno respeto y disfrute de todos los derechos humanos sólo es posible en un contexto de una situación al menos razonable de desarrollo.

Un desarrollo sustentable es aquel centrado, en definitiva, en un ser humano que disfrute y vea respetados todos sus derechos humanos.

El uso del término "desarrollo" implica más que crecimiento económico. Desarrollo comprende intereses mayores de calidad de vida, consecución educacional, estado nutricional, acceso a libertades y bienestar espiritual. El énfasis en la sustentabilidad sugiere que es necesario un esfuerzo político orientado para hacer que estos alcances de desarrollo terminen bien en el futuro. El desarrollo sustentable precisa de una serie de condiciones para que tenga lugar. En principio, el inventario de capital natural no debe disminuir en el tiempo. En este contexto, el inventario de capital natural incluye todos los activos de recursos naturales y ambientales.

Es hoy por hoy sabido que el mundo y las actividades productivas giran alrededor de la Economía, siendo una verdad dura para muchos pero en general innegable. Así las cosas, la importancia principal de la valoración

(12) SHAW, MALCOLM N., Capítulo IV, The international environmental law, *International Law*, Cambridge, 2003, p. 757 (traducción libre).

(13) Preámbulo de la Declaración sobre el derecho al desarrollo adoptada por la Asamblea General en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986.

económica de la calidad ambiental, radica en el aprovechamiento de los recursos naturales por los individuos, pero esencialmente por los sectores empresariales, que en definitiva son los encargados de dirigir las riendas del "desarrollo" humano.

6. LA AUDIENCIA PÚBLICA COMO MEDIO PROBATORIO EN LOS DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA (14)

a) Modo de introducción

Todos sabemos las bondades que ostenta la audiencia pública en la discusión de temas que atañen a la sociedad —como ser en este caso el derecho ambiental—, donde uno de los actores son los individuos y las organizaciones no gubernamentales. Más allá de que su opinión o su punto de vista no resulten obligatorios para el juzgador (ninguna prueba lo es, ya que todas se hallan sometidas a las reglas de la sana crítica), las decisiones finales deben ser adecuadas, con la obligación de la autoridad de fundamentar fáctica y jurídicamente las mismas.

Con todo ello se logra, en bastante medida, fortalecer la relación entre el Estado, las empresas de servicios públicos y la sociedad civil, además de desarrollar una democracia legítima y transparente, en aras del bienestar general.

Entre otras cuestiones, ¿resultaría imprescindible una regulación normativa al respecto para poder ser utilizada en todas las causas judiciales en donde se decida asuntos de grave trascendencia social?

b) La garantía de ser oído y la audiencia pública

La garantía de oír a las partes involucradas antes de dictar una decisión que pueda afectar sus derechos o intereses, es un principio básico del derecho constitucional y administrativo.

En nuestro país no solamente se encuentra plasmado en el art. 18 de la Constitución Nacional, sino que además contiene una regulación internacional como son: 1) El art. 8º de la Convención América de Derechos Humanos, donde establece que ".... toda persona tiene derecho a ser oída... para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter....". 2) El art. 14 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que "...toda persona tendrá derecho a ser oída..." "....para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil...".

Pero qué ocurre cuando las personas involucradas no son tan solo las partes intervinientes en el litigio, sino por el contrario son derechos que inte-

(14) V. CARNOTA, WALTER F. y MARANIELLO, PATRICIO A.: "La audiencia pública como medio probatorio en materia de derecho ambiental", en Revista de Derecho Ambiental, N° 2, abril-junio de 2005, p. 1.

resan a toda la sociedad o a la mayoría de ella. No se podría por lo tanto dictar una sentencia sin llamar a todas las personas que quieran expresar su opinión a favor o en contra de lo planteado en una causa judicial.

La audiencia pública encuentra, ante esta problemática, la solución que más se acerca a un sistema republicano y democrático que se precie de tal. El secreto, es solo un resabio medieval que las modernas democracias ya no aceptan sino en contados asuntos del Estado que hacen a la seguridad nacional, o a la discreción que debe proteger el secreto comercial.

c) El marco constitucional y legal

Queda claro que el precitado mecanismo halla su quicio en el art. 18 constitucional (derecho de defensa en juicio), en coordinación armónica y sistemática con lo que disponen los nuevos arts. 41, 42 y 43 (agregados por la reforma de 1994). Las tres últimas normas tienen a la información y a la participación como vectores fundamentales.

Cabe destacar, además, que los arts. 41 y 42 no están aislados entre sí, y que puede pensarse latamente en que todos somos "usuarios y consumidores" de un ambiente que tiende a agotarse.

Si bien la audiencia pública en el ámbito nacional se infiere de los artículos citados, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra regulado expresamente a lo largo de varios artículos como:

- Art. 30: establece como ".....obligatorio de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública.....".

- Art. 63: La Legislatura, el Poder Ejecutivo o las Comunas pueden convocar a *audiencia pública* para debatir asuntos de interés general de la Ciudad o zona, la que debe realizarse con la presencia inexcusable de los funcionarios competentes. La convocatoria es obligatoria cuando la iniciativa cuente con la firma del medio por ciento del electorado de la Ciudad o zona. También es obligatoria antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos.

- Art. 90: El procedimiento de doble lectura tiene los siguientes requisitos:

1. Despacho previo de comisión que incluya el informe de los órganos involucrados.

2. Aprobación inicial por la Legislatura.

3. Publicación y convocatoria a *audiencia pública* dentro de 30 días, para que los interesados presentes reclamos y observaciones.

- Art. 120: La Comisión competente de la Legislatura celebra una *audiencia pública* con la participación de los propuestos para el tratamiento de los

pliegos remitidos por el Consejo. Las sesiones de la Legislatura en las que se preste el acuerdo para la designación de los magistrados son públicas.

• Art. 139: El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos está constituido por un Directorio, conformado por 5 miembros, que deben ser profesionales expertos.

Los miembros del Directorio son designados por la Legislatura por mayoría absoluta del total de sus miembros, previa presentación en *audiencia pública* de los candidatos.

De esta gama de artículos los únicos específicamente establecidos para el mecanismo de audiencia pública —según lo venimos desarrollando— son los artículos 30 y 63, mientras que los restantes apuntan con mayor precisión a las convocatorias públicas o a las sesiones públicas. Las primeras se diferencian de estas últimas que los ciudadanos, las ONG y asociaciones civiles sin fines de lucro son actores principales y su opinión, si bien no vinculante, hace a la claridad y discusión de un sistema de gobierno. Mientras que los restantes no resultan obligatorios y su participación no es fundamental para la toma de decisiones, sino tan solo se le está permitida su intervención.

Otro rasgo característico de estas últimas son las reuniones populares o *town meetings*; son de carácter informal, es decir, no tiene una regulación legislativa, están abiertas para todo el público en general en forma ilimitada y se desarrolla bajo un sano intercambio de opiniones entre las autoridades y los ciudadanos. Estas son utilizadas para reemplazar las encuestas, con un contacto mucho más directo y fluido con el público.

En materia legislativa, sobre temas ambientales, los derechos de consulta y opinión, y la audiencia pública, se encuentran contemplados por los arts. 19 y 20 de la Ley General del Ambiente 25.675. En su tramo final, el último de los artículos referidos aclara que la opinión que surja no es vinculante, pero que en caso de disconformidad con el criterio de la autoridad convocante, ésta deberá fundarlo y hacerlo público.

d) La esfera reglamentaria

El art. 3° del Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional (aprobado por el decreto 1172/03), establece que "la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en el cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general exprese su opinión".

Por otro lado, el art. 4° del reglamento de marras, aclara que la finalidad de la audiencia pública es permitir y promover una efectiva participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública (sic) las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las cuestiones puestas en consulta.

Queda clara la importancia que, en la actualidad, tiene la audiencia pública como un canal más de participación ciudadana, donde se ve transformada la vieja democracia indirecta en la democracia semi-directa (en análoga dirección, ver Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-Administrativo Federal, Sala IV, "Youssefian, Martín", sentencia del 23 de junio de 1998, La Ley, 1998-D, 719).

En tal sentido, ya se había dicho que "la audiencia revela un redimensionamiento de la significación de la vertiente dinámica de la función administrativa, en su relación con la importancia del acto en tanto manifestación estática de aquella" (15).

e) Proyección jurisprudencial

El Poder Judicial sistemáticamente viene hablando de la audiencia pública, obligando al Estado —en casos específicos— a llevarla a cabo, en algunos casos bajo pena de nulidad, y en otras regulando sus alcances, por la cual se denota su buena voluntad en su futuro desarrollo y convocatoria —hasta de oficio— por los jueces, en las causas que revistan un interés colectivo.

El Fuero Contencioso Administrativo Federal ha conceptualizado y caracterizado a la audiencia pública, cuyos elementos resultan de relevante trascendencia para su mejor comprensión contemporánea del instituto.

Entre otras causas, tenemos el caso "Youssefian" (16) de la Sala IV, que trató el tema de la prórroga de exclusividad de las licenciatarias del servicio básico telefónico nacional, cuyos considerandos reproducimos a continuación:

- El instituto de la audiencia pública (que, tras la reforma del Estado dispuesta en virtud de la ley 23.696, resulta previsto en las leyes regulatorias de los servicios públicos de transporte y distribución de la electricidad y del gas y en el decreto 1185/90) constituye uno de los cauces posibles para el ejercicio de los derechos contemplados en el art. 42 de la C.N.
- La realización de una audiencia pública no sólo importa una garantía de razonabilidad para el usuario y un instrumento idóneo para la defensa de sus derechos, un mecanismo de formación de consenso de la opinión pública, una garantía de transparencia de los procedimientos y un elemento de democratización del poder, sino que resultaría una vía con la que podrían contar los usuarios para ejercer su derecho de participación en los términos previstos en el art. 42 de la C.N. antes de una decisión trascendente.
- La audiencia pública no es sino uno de los medios a través de los cuales podría tener lugar a la necesaria participación de los consumidores y usuarios con carácter previo a la toma de decisiones en el ámbito de los servicios públicos.

(15) V. COMADIRA, JULIO R., *Derecho Administrativo*, Buenos Aires, 1996, p. 249.

(16) CNFed. Cont. Adm., sala IV, *in re*: Youssefian, Martín c. E.N. - Sec. de Comunicaciones s/ amparo ley 16.986". Causa: 22.776/97 Galli, Jeanneret de Pérez Cortés, Uslenghi (por su voto) 23/06/1998 - Ref. Nor.: C.N. Art. 42.

- La regulación de un procedimiento previo al dictado de actos de alcance general que contemple la participación ciudadana es altamente beneficiosa, en orden a conseguir una mayor eficacia en la acción de los órganos administrativos y en punto a lograr un máximo grado de acierto en la decisión. La intervención en el trámite de sujetos portadores de intereses colectivos proporciona a la Administración, además de aportes técnicos, la oportunidad de realizar una valoración preventiva de las consecuencias políticas y sociales de sus actos, esto es, del agrado u oposición que puede encontrar una futura decisión. Ello, sin perjuicio de constituir una razonable reglamentación del derecho de los interesados a participar en las decisiones administrativas trascendentes que hacen al gobierno o dirección de los asuntos públicos. (Del voto del juez Uslenghi).

- La adopción del mecanismo de la audiencia pública como acto previo a la decisión de la prórroga de la exclusividad del servicio resultaría la más adecuada. Esta interpretación se condice con los objetivos tenidos en mira por la Secretaría de Comunicaciones al dictar la resolución 57/96, por la cual se aprobó el reglamento general de audiencias públicas y documentos en consulta para las comunicaciones; y, en cuanto a la trascendencia del acto a dictar y la necesidad de convocar una audiencia pública, también concuerda con lo dispuesto en el art. 6º de la ley 24.076 y lo que surge del inc. g) del art. 28 del anteproyecto de ley 1672/96 presentado el 28/8/1996 por el senador Vaca y otros.

Caso "Celadi" (17) de la Sala II del Fuero Contencioso Administrativo Federal:

- El art. 42 de la C.N. ha dejado librado al legislador la determinación, en cada caso, de los instrumentos o medios de control que se consideren más adecuados; lo cual no significa, ni surge tampoco de manera directa del texto del art. 42, que sea la audiencia pública el único y exclusivo medio idóneo a fin de que el derecho consagrado constitucionalmente pueda ser ejercido de manera eficaz (consid. 7).

Causa "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires" de la Sala V del Fuero Contencioso Administrativo Federal (18):

- La convocatoria a la realización de una audiencia pública antes de dictar resolución en materias relacionadas al derecho de los consumidores y usuarios en las relaciones de consumo es obligatoria para el Ente Nacional Regulador del Gas en los casos de abusos de situaciones derivadas de un monopolio natural o de una posición dominante en el mercado (art. 68, ap. a,

(17) CNFed. Cont. Adm., sala II, in re: "Celadi y otro c/E.N. (Secretaría de Transporte) y otros s/amparo ley 16.986". Damarco, Garzón de Conte Grand, Herrera. 10/08/2000 - Nro. Exp.: 33.196/99.

(18) CNFed. Cont. Adm., sala V, in re: "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c. Sec. de Comunicaciones (Resol. 2926/99) s/amparo ley 16.986". Grecco (en disidencia); Gallegos Fedriani, Otero. 30/08/2000. - Nro. Exp.: 40.032/99.

in fine de la ley 24.076) y para el Ente Nacional Regulador de la Electricidad en los casos de solicitudes de modificación de tarifas por parte de los transportistas y distribuidores (art. 46 de la ley 24.065). (Del voto del Dr. Otero, consid. V).

- La realización de audiencias públicas cuando se discute un régimen tarifario es necesario a fin de posibilitar a los usuarios un marco de libre debate y debida defensa de los derechos que pudieren entender afectados y una vía de ejercicio del derecho de participación instaurado por el art. 42 C.N., a fin de permitir en forma adecuada el conocimiento por parte de los aludidos sujetos de los antecedentes documentales, fácticos y jurídicos que hacen a la resolución a adoptarse, y también que las partes ofrezcan y produzcan la prueba que estimen pertinente. (Del voto del Dr. Otero, consid. V).

f) Su extensión al ámbito jurisdiccional

Los interrogantes que nos planteamos ante la necesidad que la audiencia pública sea una prueba más en las causas judiciales son: *¿quién ostenta la función de contralor de los derechos de incidencia colectiva? ¿es necesario una mayor participación o una más extenso control por parte de los ciudadanos en áreas de interés general, con una reducción en la función específica de los Poderes del Estado?*

La función específica del Poder Judicial es fallar de acuerdo a derecho y a los elementos fácticos que aportan las partes u obtiene el juez ante los múltiples elementos probatorios que solicita. Con un control de los derechos individuales, colectivos y generales, plasmados en la Constitución Nacional.

En una causa judicial, en estos últimos aspectos, la función de contralor la ostentaba exclusivamente el Estado o ciertas personas que realmente se encuentran afectadas. Es decir, no había una participación activa de todas las personas, de las asociaciones o de una persona que forma parte del Estado que defiende los intereses del pueblo —Ombudsman o defensor del pueblo—. Recién con la reforma de 1994 la legitimación activa se ha ampliado considerablemente, incorporándolos como parte de este proceso participativo y de control ciudadano.

Ante el segundo interrogante, creemos que resulta sumamente beneficioso el control y la participación del pueblo, pero con una mayor intervención del Poder Judicial como director del proceso en toda audiencia pública.

En su último libro "*La construcción del Estado*" Francis Fukuyama (19), distingue dos aspectos del Estado. Uno, al que llama "fuerza" (*strength*), tiene que ver con la capacidad del Estado para cumplir sus funciones de control. El otro al que denomina "alcance" (*scope*), tiene que ver con las áreas que pretende abarcar el Estado. Lo característicos de los Estados de los países subdesarrollados es, según el autor, que tienen mucho *scope* y poco *strength*. Lo

(19) *State-Building: Governance and World Order in the 21st. Century*, Ithaca, New York, 2004.

característico de los Estados de los países desarrollados es, al contrario, que limitan su *scope* a las áreas donde pueden mostrar su *strength*, porque saben que el que mucho abarca poco aprieta (20).

En los procesos de daño ambiental, aumentos tarifarios o de extensión de exclusividades de los servicios públicos, por ejemplo, aumenta el *scope* hacia el Poder Ejecutivo Nacional, pero el *strength* choca con la realidad, ya que no pueda tener la capacidad de ser juez y parte; queremos decir con esto, que negocia por un lado con las empresas concesionarias y por el otro decide. Son los usuarios a través de la justicia los que verdaderamente tendría que ostentar el *strength*.

Ahora bien, ello sería incompleto si tan solo se utiliza en procesos decisivos de la Administración Pública y no en el Poder Judicial, imposibilitando una herramienta imprescindible para los jueces, en los casos en que la resolución de un conflicto requiera escuchar la opinión y puntos de vista de la sociedad, para un mejor y más eficaz manejo de la causa.

Para ello necesitamos que la audiencia pública pueda ser utilizada por los jueces como medio probatorio, es decir, cuando se llama a audiencia preliminar y/o se abra la causa a prueba en un expediente judicial concreto. Deviene importante establecer que en la producción de las pruebas solicitadas por las partes, se incluyan en los casos señalados precedentemente, la sustanciación de prueba a través de la audiencia pública, dirigida y convocada por el juez de la causa. Con la posibilidad de que sea estipulada sin petición de las partes, tan solo por el juez de oficio.

g) Beneficios que encuentra la doctrina en las audiencias públicas

Agustín Gordillo es sin lugar a dudas el autor que más ha escrito en nuestro país y también uno de los principales defensores de su utilización dentro del Estado.

El citado jurista considera que la implementación de la audiencia pública permite: a) al interés público que no se produzcan actos ilegítimos y b) al interés de los particulares, poder influir con sus argumentos y pruebas antes de la toma de una decisión determinada; también sirve empíricamente c) a las autoridades públicas para disminuir el riesgo de posibles errores de hecho o de derecho en sus decisiones, con el consiguiente beneficio en la eficacia de sus acciones y el consenso que ellas puedan acarrear en la comunidad (21).

Desde otra perspectiva, la participación en audiencia pública, o mediante otra modalidad participativa, en forma previa al dictado de los regla-

mentos, consagra la función democratizadora del procedimiento administrativo (22).

Para Jean Rivero, la audiencia pública es un elemento de democratización del poder, conforme al ya clásico principio de que ya la democracia es no sólo un modo de designación del poder, sino también un modo de ejercicio del poder (23).

Según Wade, la regla que exige una audiencia es de validez casi universal. Puede ser planteada sin incompatibilidad desde su nativo suelo judicial a cualquier parte del campo de la administración, "... esta regla abarca toda la noción del procedimiento legal (*fair procedure*), o debido proceso, y es apta de gran elaboración en detalle..." (24).

Reafirmando lo que ya hemos adelantado, con todos estos beneficios, el Poder Judicial no puede dejar de lado su utilización en causas judiciales como un medio probatorio más, en beneficio de una mejora democrática de sus decisiones judiciales, respetando el derecho de defensa de todos los ciudadanos.

h) Recapitulaciones

El "debido proceso adjetivo" se vería notablemente fortalecido si a la vez de emplearse en sede administrativa, las audiencias fuesen usadas habitualmente ante los tribunales de justicia. Los principios procesales de *concentración*, *inmediación* y *economía procesal*, entre otros, saldrían airoso y beneficiados.

Debe destacarse que el conocimiento personal del magistrado de las posiciones esgrimidas por las partes a través de sus propias impresiones es un elemento valioso e insustituible a la hora de tener que formar convicción sobre sus pretensiones jurídicas.

En tal sentido, el art. 32 de la ley 25.675 ya cit. en lo pertinente prescribe que: "...El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general... En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrá solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte".

(22) SACRISTÁN, ESTELA B.: "Audiencia pública y otros procedimientos consultivos en el dictado de actos administrativos de alcance general (nulidades por su omisión)", Rev. de Derecho Administrativo n° 30/31, ps. 169-193, esp. p. 191.

(23) RIVERO, JEAN, *Droit administratif*, 4ª ed. París, 1970. p. 827 y sgtes. Opinión extraída de AGUSTÍN GORDILLO tratado citado.

(24) WADE, H.W.R., *Administrative Law*, Oxford, 1961, p. 141.

(20) GRONDONA, MARIANO, "La izquierda y la derecha necesitan que haya Estado", diario La Nación del 20 de febrero de 2005.

(21) GORDILLO, AGUSTÍN, "El procedimiento de audiencia pública", Revista de la Administración Pública, N° 214, Sección Doctrina, ps. 5/17.

74

Podemos colegir (interpretación *a contrario sensu*) que si el sentenciante posee tan amplias potestades en el contencioso ambiental (25), aún sin oír a todos los litigantes en el proceso, bien puede ordenar la realización de audiencias en su juzgado que garanticen la bilateralidad y la contradicción.

La forma ideal para la implementación del régimen de audiencias públicas en el campo judicial (26) sería su incorporación en el Código de Procedimiento respectivo, en el capítulo atinente a las pruebas, y allí regular su objetivo, finalidad y procedimiento. Pero no dejamos de meritar que ello puede también encajar a la perfección en la economía del apuntado art. 32 y en las facultades instructorias que el art. 36 de la ley de rito civil confiere al juez como director del proceso (27).

Concluimos en que la aplicación de esta modalidad hará que se cumplan con la Declaración de Río en sus Principios 10 y 11, en cuanto exigen a los Estados promulgar "leyes eficaces" en la protección ambiental y proporcionar un "acceso efectivo" a los procedimientos administrativos y judiciales respectivos.

7. LOS TRIBUNALES JUDICIALES AMBIENTALES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (28)

a) Introducción

El acceso a la jurisdicción no finaliza con tener un poder judicial para iniciar acciones judiciales y obtener una decisión contra la alteración de los derechos. Esto requiere además de un procedimiento y una sentencia que dé respuesta a cuestiones muy específicas por medio de tribunales especializados en la materia que se trate.

Por ejemplo el art. 39 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, establece tribunales especializados para solucionar los conflictos laborales. Como se verá, la especialidad es el elemento que mejor se acerca a la tutela judicial efectiva (art. 15), con sentencias elaboradas por verdaderos especialistas en la materia, y si ello lo llevamos al tema ambiental, la especialidad es una cuestión cardinal.

(25) Tomamos esta expresión del derecho francés. V. ROMI, RAPALE, "Droit de l'environnement: l'épreuve de l'alternance", en *Revue du droit public*, París, julio/agosto de 1994, p. 1198.

(26) Gordillo se encarga de enfatizar que "el principio de la audiencia pública es de rai-gambre constitucional". Conf. GORDILLO, AGUSTÍN, *Tratado de Derecho Administrativo*, Buenos Aires, 2003, tomo II, cap. XI, p.3.

(27) Agregamos que por la Acordada 28/04, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la actuación frente a sus estrados de "amici curiae" sin norma procesal expresa habilitante. Asimismo, la Corte reguló un régimen de audiencia pública mediante la Acordada 30/07.

(28) V. MARANIELLO, PATRICIO A., conferencia en el III Congreso Nacional de Derecho en la Ciudad de Mar del Plata, el día 23 de septiembre de 2006.

Ante la acertada creación de tribunales ambientales propugnada en un proyecto presentado en la Ciudad de Buenos Aires, se ha abierto el debate. Analizar la opinión a favor y en contra de su articulado servirá para el pluralismo y la perfección del sistema en su conjunto.

b) Situación en el derecho comparado

Sin un tribunal especializado muchos delitos ecológicos no son sancionados en América Central, por falta de recursos y peritos especializados. Mientras tanto, la región sufre una acelerada degradación del ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales (29).

El istmo concentra ocho por ciento (8 %) de la superficie de los manglares del mundo y casi doce por ciento (12 %) de las costas de América Latina y el Caribe, pero sufre una acelerada degradación del ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales.

Los fiscales ambientales son un eslabón fundamental, pero aún débil, del tejido jurídico creado para preservar la naturaleza en América Central. Son escasos y actúan en condiciones precarias, según un sondeo realizado por Tierramérica.

Honduras tiene nueve (9) fiscales, Guatemala trece (13) y Costa Rica tres (3), mientras en Panamá no existe esa figura. También funcionan fiscalías ambientales en Paraguay, Honduras y México (30).

b.1) Guatemala

Sólo dos oficinas con trece (13) fiscales, incluidos auxiliares, tienen a su cargo más de dos mil trescientos cincuenta (2350) casos por delitos contra el ambiente en Guatemala, sin respaldo de peritos y con escasos recursos económicos para llevar a juicio a los responsables, dijo Héctor Flores, Jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente de ese país, creada en 1996.

Ambas oficinas pertenecen al ministerio público. Una tiene su sede en la capital, y cuenta con cinco fiscales y tres agentes para atender el setenta por ciento de los casos del país. La otra, en el septentrional departamento del Petén, dispone de tres auxiliares fiscales y dos oficiales.

b.2) Honduras

En Honduras, la falta de personal especializado limita el avance de las investigaciones y la aplicación de leyes, según Aldo Santos, fiscal del Medio Ambiente.

(29) GROCHEMBAKE JORGE A. y MEJIA THELMA, "Sequía de fiscales ambientales". <http://www.tierramerica.net/2003/0519/acentos2.shtml>

(30) V. CAFFERATTA, NÉSTOR A., "La necesidad de fiscalías ambientales", en *www.eldial.com*, Suplemento de Derecho Público bajo la dirección de WALTER F. CARNOTA, noviembre de 2006.

Existen nueve fiscales con amplia formación en todo el país, cinco en Tegucigalpa, la capital.

Fundada en 1994, la Fiscalía Ambiental permitió romper hasta cierto punto el círculo de impunidad en materia ambiental, pues antes ningún caso llegaba a los tribunales, dijo Santos.

Debido a que los delitos ecológicos son de naturaleza distinta a los del fuero ordinario, su castigo requiere un trabajo especializado de investigación, con respaldo forense y manejo pericial técnico y profesional en laboratorios. Sin embargo, "tenemos apenas cinco técnicos que nos apoyan en este tipo de labores a nivel nacional", explicó el funcionario citado.

Este reducido personal tiene en sus manos unos 250 procesos penales. Pero las investigaciones no suelen profundizar en las causas de los delitos ambientales, aseguró.

b.3) Costa Rica

La historia se repite en Costa Rica, donde la Fiscalía Ambiental, creada en 1993, carece de una unidad de especialistas.

En Honduras y Costa Rica los fiscales son apoyados por personal de los ministerios de Ambiente y de otras dependencias relacionadas.

Costa Rica cuenta con las leyes ambientales más antiguas de América Central, destacó el coordinador de la Fiscalía Ambiental, Sergio Valdelomar. Para las tareas de recibir denuncias, investigar y acusar "disponemos de toxicólogos que realizan peritajes en varias materias, pero carecemos de peritos especializados", explicó.

La fiscalía requiere expertos propios para evitar costosos pagos a peritajes privados en casos de contaminación de aguas, por ejemplo, dijo Valdelomar. La institución ofrece además capacitación a los jueces para integrar aspectos jurídicos y conocimientos científicos.

Ana Victoria Rojas, especialista del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDERENA), con sede en San José, consideró un problema que en el país existan sólo tres fiscales ambientales especializados.

La creación de la Fiscalía permitió mejorar la persecución de delitos y activó la capacitación en la materia, reconoció. Pero la labor de preparar a los magistrados obliga a dejar pendientes las causas en fase de investigación, advirtió.

b.4) Panamá

Mientras tanto en Panamá, delitos como tala indiscriminada de árboles, contaminación de ríos y playas y caza ilegal de especies en peligro no son sancionados e incluso no llegan a ser investigados, según Francisco Rivas,

portavoz de la Red de la Asociación para la Promoción de Nuevas Alternativas de Desarrollo.

La acción legal contra delinquentes ambientales compete a los corregidores, quienes están bajo la jurisdicción de los alcaldes y carecen de real investidura para actuar ante el delito, así como de la debida información y capacitación, aseguró Rivas.

b.5) Brasil

Las instituciones brasileñas son eficaces, aunque su capacidad está limitada por la escasez de agentes efectivos, aseguran las organizaciones ambientalistas. El gubernamental Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) cuenta con 1500 inspectores, que se suman a las policías ambientales de los gobiernos estatales.

En muchas localidades de la Amazonia brasileña —un territorio de 4,9 millones de kilómetros cuadrados que alberga la mayor diversidad biológica del mundo—, los inspectores del IBAMA son "el único rostro visible del Estado", dijo a Tierramérica Paulo Adario, coordinador de la campaña amazónica de Greenpeace.

b.6) España

Un informe sobre las fiscalías ambientales de España señala que "los fiscales del ambiente, disponen, lógicamente, de tiempo específico para investigar este tipo de delitos, pero sobre todo disponen de especialización, tanto jurídica como técnica, en esta materia. Esto es muy importante porque la averiguación de los autores de estos delitos, la determinación de daño o, en su caso, del peligro para el ambiente o el examen de las normas administrativas aplicables para la configuración de muchos de estos tipos penales presentan particularidades notables y no son normalmente tareas fáciles y a las que estén acostumbrados los fiscales". "En los delitos ambientales además, es fundamental la intervención del Ministerio fiscal puesto que, así como en otros tipos de delitos suele haber perjudicados, dañados u ofendidos, en los relativos al ambiente muchas veces no los hay y, aunque la acción penal siempre es pública, en estos casos no la suele ejercitar nadie. Las asociaciones ecologistas están normalmente desbordadas en su labor de iniciar acciones legales de defensa de la legalidad ambiental. En muchas ocasiones, ante hechos claramente delictivos no pueden hacer otra cosa que presentar denuncias ante los juzgados, ya que interponer querellas no suele ser viable por la dificultad de obtener pruebas para imputar a los autores, por la frecuente imposición de fianzas impagables o por las costas procesales".

c) Opinión de la doctrina especializada

Según explicó Fígoli, la iniciativa legislativa busca "establecer una serie de normativas que van desde la creación de un tribunal ambiental —que se

especialice en el juzgamiento de las actas ambientales desde lo administrativo— hasta la especialización de los encargados de los controles” (31).

Los nuevos tribunales resolverían los recursos de apelación luego de un acta por una contravención en cuestiones ambientales, “como el exceso de decibeles permitidos, que es uno de los problemas más graves que tenemos. La idea es obtener una Justicia más específica, que eduque y que prevenga”, señaló.

La especialista española Silvia Jaquenod de Zsögön coincidió: “Hay que trabajar en la prevención para evitar las sanciones porque, cuando sancionamos, ya el daño ambiental está ocasionado. El ámbito penal debe ser el último escalón al que hay que llegar (32).

Por ello, lo fundamental para la prevención es la formación. Como juristas, no deberíamos pretender saberlo todo, pero sí tener la capacidad suficiente como para detectar el momento en que necesitamos rodearnos de un equipo interdisciplinario que nos asesore. Deben estar formados los jueces, fiscales y los funcionarios políticos. No tienen que ser superhombres en materia ambiental, pero deben saber a quién recurrir. Si no tienen la formación, pues que se rodeen de un equipo. No es posible que haya causas judiciales que tarden cinco años en decidirse, eso sucede por la falta de formación. Porque mientras se busca una respuesta a la acción entablada, el proceso de deterioro ambiental continúa. Por otra parte, de la mano de la formación está la información, que genera conocimiento. Y en ese sentido los medios de comunicación tienen parte de la responsabilidad, porque se si informa se está previniendo.

Eso además permite la participación pública. Y son necesarias fuertes campañas de sensibilización ambiental constante. Debe ser una actitud del Gobierno, de las universidades. La universidad no ha asumido aún la variable ambiental. Y eso no es porque es muy reciente, podemos mencionar ya un digesto del siglo VI. Y hay registro de penalidades en 1748 para los causantes de incendios, que iban de multas hasta la cárcel o el destierro, además, claro está, del famoso caso de los “Saladeristas” de nuestra Corte del s. XIX (Fallos: 31:273).

d) Proyecto en la Ciudad de Buenos Aires

Como dijimos, existe un proyecto de creación de los tribunales ambientales en el ámbito de la Ciudad de Bs. As. Este consta de 79 artículos, donde se crean Tribunales Ambientales que estarán integrado por tres jueces, no pudiendo ser todos del mismo sexo (33).

(31) Opinión vertida en el seminario sobre “Tribunales Ambientales en la Ciudad de Buenos Aires” organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Bs.As, celebrado el día martes 15 de agosto de 2006.

(32) http://www.proyectogeo.com/noticias/nt_pages/nt_35585.asp

(33) Nos parece sumamente interesante esta cláusula antidiscriminatoria, porque no protege a la mujer sino a ambos sexos, donde no obliga a establecer un cupo de mujeres determinadas sin evaluar la necesaria cantidad unida a la capacidad.

Un proyecto que se debate en la Legislatura porteña propone la creación de tribunales ambientales, que estarán dedicados a investigar y juzgar sólo cuestiones relacionadas con contaminación. Estos tribunales especializados tendrán como función el juzgamiento y el control de las actas ambientales.

d.1) Principio de gratuidad

En el art. 11 del proyecto enumera los principios que se regirán en estos procedimientos y entre ellos se encuentra el de gratuidad.

Para cumplir con este principio se encuentran los siguientes artículos: 13 (asistencia jurídica gratuita), 14 (asesoramiento gratuito en cada comuna), 15 (no tributación de tasa de justicia) y 16 (las costas del juicio son soportadas en el orden causado, con excepción de temeridad y malicia).

Todos los artículos citados se relacionan con el principio de gratuidad y hacen a que no sea sólo una pauta aislada. Por el contrario, se encuentra cubierto en todos sus aspectos. Excepto el art. 16 donde determina que las costas son soportadas en el orden causado, esto no hace a la gratuidad en sentido estricto atento que si la parte actora pierde el juicio es correcto que no pague las costas de su parte alterando el principio de gratuidad, pero no que la parte demandada, quien produjo el daño ambiental, no cargue con las costas.

Finalmente otra norma que viola la doble instancia es el art. 59 donde transforma en inapelables los montos inferiores a \$100.000, produciendo sentencia definitiva en un tema tan importante en su esencia misma.

d.2) Impulso de oficio

El art. 23 inc. e) marca como deber del juez impulsar de oficio el procedimiento, es decir, el juez no sólo no debe permitir la paralización del proceso, la caducidad, etc., sino además está obligado a suplir a la parte en toda negligencia o atraso del procedimiento, agilizándolo a los efectos de lograr la tutela judicial efectiva.

Aquí el juez no es tan solo un árbitro o mediador en el procedimiento sino que está involucrado a los efectos de proteger el interés general, ya que suple a la parte e investiga en aras de un derecho ambiental sustentable para todos.

e) Conclusión

Hoy el perfeccionamiento judicial no sólo apunta a que la solución perdone en el tiempo, sino que además requiere el certero y preciso respeto del principio de la especialidad judicial, porque no sólo se busca acceder a la justicia, sino que además se necesita de una sentencia elaborada por especialistas en la materia y no una simple resolución, para así dar respuesta a los justiciables.

La temática ambiental exige un completo abordaje jurisdiccional, que excede los clásicos moldes y formas. En efecto, la problemática de la “tutela

jurisdiccional del ambiente" es de suyo muy variada, requiriendo una profusa actividad probatoria, participación útil de los interesados, agilidad de los procedimientos, "expertise" y "know-how".

Bien apunta Lorenzetti que el paradigma ambiental "crea un nuevo escenario de conflictos entre el ambiente, ubicado en la esfera social, y los derechos individuales, generando un modo de interrelación diferente y una lógica distinta de solución del conflicto" (34).

Por lo demás, es urgente "continuar con los cambios en materia de legitimación procesal de los litigios ambientales de naturaleza civil y, en los términos más generales de adaptación del proceso civil a las necesidades de las acciones colectivas" (35).

Los delitos contra el ambiente no tienen quién los persiga en la región, pues sólo Brasil cuenta con una policía ambiental de limitado alcance. Otros países recurren al ejército o las policías que no están preparados para esa misión (36).

En nuestro país necesitamos Tribunales Ambientales que cuenten con un cuerpo de peritos propio conformado por técnicos especializados en estos temas y que hacen al necesario enfoque multi e inter disciplinario que el fenómeno ambiental convoca. No existe en la actualidad un cuerpo de peritos ambientales a los cuales acudir cuando se necesita un informe válido para presentar en juicios ambientales.

En cuanto a la actitud actual de los jueces, bastarán un par de ejemplos, en cuestiones que hemos seguido de cerca:

Durante la última década se produjeron 300 incendios intencionales en la reserva Ecológica Costanera Sur, sin ninguna intervención de la Justicia. Sin embargo, en muchos casos el personal de la Reserva había capturado a los incendiarios y aún los había filmado. Entregadas las pruebas al juez respectivo, los había puesto en libertad sin interrogarlos ni abrir ninguna causa. La intervención de la Justicia por primera vez en un incendio de la Reserva, fue el número 301, luego de una activa campaña por parte del defensor del pueblo. Está claro que se necesita otra conducta por parte de los jueces ante los asuntos ambientales (37).

En el caso de la estación de servicio de Lima e Independencia de la Ciudad de Buenos Aires, que contaminó el suelo hasta el punto de que gotea

(34) V. LORENZETTI, RICARDO LUIS, *Teoría de la Decisión Judicial (Fundamentos de Derecho)*, Buenos Aires y Santa Fe, 2006, p. 467.

(35) BRAÑES, RAÚL, "El acceso a la justicia ambiental en América Latina y la legitimación procesal en los litigios civiles de naturaleza ambiental en los países de la región", en AA.VV., *Justicia ambiental (las acciones judiciales para la defensa del medio ambiente)*, Bogotá, 2001, p. 370.

(36) OSAVA MARIO, "Policía verde, rara avis de América Latina". <http://www.tierramerica.net/2002/0616/articulo.shtml>

(37) Fundamentos del proyecto de ley de la Ciudad de Bs.As. sobre los tribunales ambientales.

nafta en la estación del subterráneo, hay una causa por daños ambientales que se abrió hace 24 años y tiene sentencia firme con orden de remediación de la zona afectada (unas dos o tres hectáreas bajo la Avenida 9 de Julio). A pesar de la peligrosidad del caso (agravado por tratarse del interior de una gran ciudad), en ningún momento la justicia ordenó levantar los tanques de combustible para ver en qué estado está el suelo debajo de ellos y si hay o no riesgo de explosiones. Y tuvo 24 años para hacerlo.

Es por todo ello que la creación de mayores inspectores resulta de una importancia muy significativa para que puedan llegar más y mejor presentaciones ante un fuero especializado en la materia, pues no solo hay que proteger el derecho ambiental sino la tutela judicial efectiva, que recuerda que toda sentencia para ser válida debe ser oportuna y eficaz, y eso se logra —como se dijo— con la creación de un fuero ambiental.

Se ha dicho con razón que "es de la mayor premura institucionalizar *fiscalías ambientales* para que procedan de oficio, denunciando y persiguiendo pública y penalmente a todo aquel que dañe el ambiente utilizando irracionalmente recursos naturales (aire, agua, tierra, minerales, bosques, floras, faunas, etc.)" (38).

En América tenemos una gran cantidad de fiscalías ambientales, pero no tenemos un verdadero Poder Judicial Ambiental, pues si bien la investigación y acusación se encuentra localizado en los fiscales, la decisión final no está en manos de magistrados judiciales especializados (39). Es de destacar que, en la órbita del ministerio público fiscal federal, la Procuración General de la Nación ha implementado desde abril de 2007 una Unidad Fiscal del Medio Ambiente, tal como lo había propiciado la doctrina especializada (40).

El proyecto presentado en la Ciudad de Buenos Aires, que crea un verdadero fuero ambiental, es un buen comienzo. Pero como dice la famosa canción: "caminante no hay camino, se hace camino al andar".

(38) V. BERTOSI, ROBERTO F., "Fiscalías Ambientales", ED, 217-600.

(39) Parecería de todos modos que gradualmente se podrían implementar fiscalías ambientales, para luego instrumentarse el fuero ambiental. Ver, en sentido concordante, CATALANO, MARIANA, "Fiscalías Ambientales. Necesidad de la figura", LA LEY, Columna de Opinión, 28 de febrero de 2007.

(40) V. CAFFERATTA, NÉSTOR A., "La necesidad de fiscalías ambientales", art. cit.

CAPITULO IV

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD

SUMARIO: 1. Preliminar. — 2. Concepto y características. — 3. Regulación normativa. a) Constitución Nacional. b) Tratados Internacionales. c) Legislación. — 4. Igualdad formal versus igualdad real o material. La no discriminación. — 5. Igualdad ante el Estado y ante los demás particulares. — 6. Las medidas de acción positiva como derivación de la igualdad real. — 7. Discriminación inversa.

1. PRELIMINAR

Uno de los derechos básicos y más eminentes consagrados por el movimiento del constitucionalismo clásico a fines del siglo XVIII ha sido el de *igualdad*. Se trata de un concepto polémico y complejo, mucho más de lo que aparenta superficialmente, dado que a veces se lo ha contrapuesto con otros derechos, fundamentalmente con la libertad.

De la mano de la revolución francesa, este derecho se erigió como bandera de guerra frente a los abusos registrados por el "Antiguo Régimen". En este sentido, el art. 1º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789 es sumamente diáfano: "*Los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en la utilidad común*".

Amén de las discusiones del valor como precedente de este último documento, cabe destacar que no vemos así destacada a la igualdad dentro de la economía preceptiva de los primeros documentos del constitucionalismo norteamericano.

Ni la Declaración de Virginia de 1776 ni la Primer Enmienda de 1791 la consagran, aunque sí lo hace la Declaración de la Independencia del 4 de julio de 1776: "todos los hombres son creados iguales". Recién la Enmienda XIV a la Constitución norteamericana, posterior a la Guerra de Secesión, le va a dar consagración suprema a la "igual protección de las leyes" (inc. 1) (1868).

De estas primeras referencias, la igualdad se difunde a la casi totalidad de los textos constitucionales del s.XIX y del s.XX, aunque con matices importantes a partir del advenimiento del llamado "constitucionalismo social".

2. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

En el plano de la naturaleza, los seres humanos son esencialmente desiguales. La edad, sexo, altura, contextura física, estado de salud, raza, difieren de persona en persona. Asimismo, en el marco de las relaciones sociales también se advierten nuevas desigualdades en la aptitud intelectual y capacidad moral de los individuos (1).

La *igualdad jurídica*, que es aquella tutelada por la Constitución Nacional, no se propone suprimir dichas desigualdades en forma absoluta, pero tampoco aceptarlas en su totalidad. La igualdad constitucional no importa borrar las diferencias que la misma naturaleza impone entre los hombres y que deben ser respetadas, porque de lo contrario se los sometería a un trato igualitario ante distintas circunstancias y situaciones, conduciendo paradójicamente a una irritante e injusta desigualdad (2).

En definitiva, la igualdad jurídica significa que *todos los hombres están reconocidos como titulares de derechos y obligaciones, que son iguales bajo las mismas circunstancias y las mismas condiciones razonables frente al poder estatal*. En otras palabras, la igualdad jurídica consiste en que *la ley debe ser igual para todos los iguales que estén en las mismas circunstancias, y que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias* (3).

La regla de igualdad no es absoluta, ni obliga al legislador a desdeñar la diversidad de circunstancias, condiciones o diferencias que pueden presentarse a consideración; lo que aquella regla estatuye es la obligación de igualar a todas las personas afectadas por una medida, dentro de la categoría, grupo o clasificación que les corresponda, *evitando distinciones arbitrarias u hostiles* (4).

Para evaluar si una discriminación es compatible con el principio de igualdad, debe utilizarse la regla de *razonabilidad* (ver *infra*): el legislador puede crear categorías, grupos o clasificaciones que irroguen trato diferente entre los habitantes, siempre y cuando el criterio empleado para discriminar sea "razonable".

Por el contrario, *las únicas desigualdades inconstitucionales son las arbitrarias*, entendiendo por ello las que carecen de toda razonabilidad, las persecutorias, las hostiles, las que deparan indebidos favores o privilegios respecto de personas o grupos de personas.

(1) SABSAY, DANIEL DIRECTOR, coordinadores: PATRICIO MARANIELLO y otra, *Análisis jurisprudencial en el Derecho Constitucional*. Buenos Aires, 2002.

(2) LINARES QUINTANA, SEGUNDO V., *Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional*, t. 4, p. 252, Buenos Aires, 1978.

(3) BADENI, GREGORIO, *Derecho constitucional*, Buenos Aires, 1993, p. 242.

(4) BIDART CAMPOS, GERMÁN J., *Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino*, Buenos Aires, 1994, t. I, p. 386.

3. REGULACIÓN NORMATIVA

a) Constitución Nacional

Es sabido que el principio constitucional fundamental referido a la igualdad está contenido en el art. 16 de la Constitución Nacional, que prohíbe la discriminación por razones de sangre, nacimiento, prohíbe los fueros personales y los títulos de nobleza; establece que todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad; dispone, por último, que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Sin embargo, la citada disposición constitucional se complementa con otras normas (algunas de ellas incluidas por la reforma constitucional de 1994) que también desarrollan el principio de igualdad:

- El art. 8° dispone que los ciudadanos de cada provincia gozan de los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadanos en las demás.
- El art. 14 reconoce igualitariamente a todos los habitantes de la Nación el goce de las libertades fundamentales que enumera.
- El art. 14 bis asegura a todos los trabajadores igual remuneración por igual tarea.
- El art. 15 prohíbe la esclavitud y los contratos de compra y venta de personas.
- El art. 20 iguala a los extranjeros y los ciudadanos de la Nación, al asegurarles el goce de los derechos civiles.
- El art. 37 establece la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios, que se garantizará con acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.
- El art. 43. Podrá iniciarse esta acción contra cualquier acto de discriminación. Además al regular la acción de amparo, confiere legitimación activa al afectado, al defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines —registradas conforme a la ley— contra cualquier forma de discriminación (párrafo primero). En estos casos, si bien el género es el amparo, la especie es el amparo colectivo.

Por otro lado, al regular la acción de habeas data, posibilita a toda persona exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de sus datos en caso de discriminación (segundo párrafo). Aquí se incorporan los llamados "datos sensibles" que por el solo hecho de encontrarse sin el resguardo respectivo trae aparejado una vulneración latente del derecho de igualdad.

- Los arts. 4º y 75 inc. 2 establecen la proporcionalidad de las contribuciones que imponga el Congreso. La distribución de su producido atenderá, entre otros factores, a la "igualdad de oportunidades en el territorio nacional".
- El art. 75 inc. 19 dispone que corresponde al Congreso promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones; y sancionar leyes de organización y de base de la educación que aseguren la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna.
- El art. 75 inc. 23 establece como competencia del Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad.

b) Tratados internacionales

Asimismo, la reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía constitucional a distintos tratados internacionales de derechos humanos en su nuevo art. 75 inc. 22, y muchos de ellos regulan expresamente el principio de igualdad.

En tal sentido, el principio de igualdad es consagrado y desarrollado por los distintos instrumentos:

- La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
Art. II:

Todas las personas son *iguales* ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos,

Art. 10:

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena *igualdad*, a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Art. 21 inc. 2)

Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de *igualdad*, a las funciones públicas de su país.

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Art. 3º:

Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

Art. 25:

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el art. 20, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

Inc. c)

Tener acceso, en condiciones generales de *igualdad*, a las funciones públicas de su país.

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos,

Art. 1º. Obligación de respetar los derechos.

1º) Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, *sin discriminación* alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica nacimiento o cualquier otra condición social.

2º) Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Art. 8º. Garantías judiciales

Inc. 2º) Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena *igualdad*, a las siguientes garantías mínimas:

a) Derecho del inculcado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) Comunicación previa y detallada al inculcado de la acusación formulada;

c) Concesión al inculcado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) Derecho del inculcado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculcado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

Art. 17. Protección a la familia

2º) Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de *no discriminación* establecido en esta Convención.

4º) Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la *igualdad* de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.

5º) La ley debe reconocer *iguales* derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

- La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en sus arts. 1º (inc. 1º) y 5º, se refiere específicamente a la discriminación por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico.
- La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en sus arts. 1º, 2º y concs., consagra iguales principios para la mujer al nivelarla en el goce y ejercicio de los derechos que a los hombres corresponden.
- La Convención sobre Derechos del Niño insiste en su art. 2º en la cláusula igualitaria y en la eliminación de discriminaciones respecto del niño como de sus padres, tutores o familiares.

c) Legislación

Existen distintas leyes que desarrollan el principio de igualdad, y entre ellas se encuentra la ley antidiscriminatoria 23.592, sancionada en el año 1988.

Dicha ley contiene disposiciones que sancionan civil y penalmente las conductas discriminatorias arbitrarias que impidan, obstruyan, o de algún modo menoscaben el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución. Se reputan especialmente como actos u omisiones discriminatorias los basados en motivos tales como *raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social, o caracteres físicos*.

En la ley marco de Regulación de Empleo Público Nacional, 25.164, en su art. 4º, donde establece los requisitos para el ingreso a la Administración Pública Nacional, expresa su inc. c) que todo sujeto previamente deberá acreditar las condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de *igualdad* en el acceso a la función pública. El convenio colectivo de trabajo deberá prever los mecanismos de participación y de control de las asociaciones sindicales en el cumplimiento de los criterios de selección y evaluación a fin de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades.

El art. 16 de la misma ley establece la igualdad no ya como un requisito sino como un derecho de oportunidad en la carrera administrativa. La presente enumeración no tiene carácter taxativo, pudiendo ser ampliada por vía de la negociación colectiva.

En síntesis, la igualdad jurídica que prevé la Constitución, los tratados internacionales y la ley antidiscriminatoria, significa que la ley debe ofrecer iguales soluciones para todos los que se encuentran en igualdad de condiciones y circunstancias. Asimismo, que no se pueden establecer excepciones o privilegios que reconozcan a ciertas personas lo que en iguales circunstancias, se desconozca respecto de otras. Finalmente, que las discriminaciones o desigualdades que resulten de la ley no deben ser arbitrarias, sino razonables y justas (5).

4. IGUALDAD FORMAL VERSUS IGUALDAD REAL O MATERIAL. LA NO DISCRIMINACIÓN

El constitucionalismo clásico se ha caracterizado por su alto valor formal, declaracionista o declamatorio. En síntesis, la preocupación principal del mismo fue la consagración escrita de los derechos, en procura de una mayor seguridad jurídica y previsibilidad de las conductas sobre todo de los detentadores del poder.

Al primer constitucionalismo, no le importaba demasiado los mecanismos para tornar efectivos los derechos, sino tan solo poder expresarlos y dejar constancia escrita de esa manifestación, en un documento con jerarquía fundamental y con dificultades para su reforma (notas de supremacía y de rigidez constitucionales, respectivamente).

Con el correr del tiempo, en especial con el trastocamiento de las relaciones sociales generadas por el fenómeno de la Revolución Industrial, se advirtió que ese enfoque era totalmente insuficiente, pudiendo presentarse situaciones injustas amparadas sin querer por la letra de la legalidad objetiva.

Una de las reivindicaciones del llamado "constitucionalismo social" es precisamente orientarse hacia soluciones jurídicas que tengan vigencia so-

(5) BADENI, ob.cit., p. 243.

ciológica o real, y que no se limiten a la "hoja de papel" de la que hablaba Fernando de La Salle.

El acento o énfasis que el constitucionalismo social coloca en el salario, en las condiciones laborales, en las asociaciones gremiales, van direccionadas hacia el rumbo de lograr un mayor equilibrio, en especial en la relación entre empleador y empleado.

Ya luego de 1945 se va a proyectar el tema de la igualdad no sólo en el campo laboral, sino que se procurará *evitar las discriminaciones* en todos los planos, discriminaciones que tanto daño habían hecho durante la II Guerra Mundial. Así, la igualdad asume un nuevo ropaje, como derecho a la no discriminación, por razones políticas, religiosas, étnicas o nacionales, de edad, etc.

Como ya señalamos "ut supra" un claro ejemplo de ello lo configura la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, cuando prohíbe distinciones basadas en la "raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".

5. IGUALDAD ANTE EL ESTADO Y ANTE LOS DEMÁS PARTICULARES

Cabe destacar que la igualdad no sólo debe ser garantizada ante el legislador, como escuetamente reza el artículo 16. Si bien el legislador debe ser especialmente cauto de no introducir distingos odiosos, la directiva también se proyecta a la Administración y al juez. Por lo tanto, la igualdad ante el Estado se descompone en:

- igualdad ante la ley,
- ante la Administración,
- ante la jurisdicción y,
- ante y entre particulares.

Un campo nuevo y fértil en esta materia lo configura la igualdad ante y entre particulares. En efecto, la discriminación en el empleo, en el acceso a locales, en las diversas formas de contratación (p.ej. en los alquileres), presenta día a día supuestos complejos en donde cabe balancear o equilibrar el derecho a la igualdad con otras potestades subjetivas (libertad de comercio y de industria, de trabajar, de contratar, de asociarse) que también gozan de protección y alcornia constitucional.

6. LAS MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA COMO DERIVACIÓN DE LA IGUALDAD REAL

En varios tramos, la reforma constitucional de 1994 abunda en el concepto de la "igualdad real de oportunidades y de trato".

Un claro ejemplo de esta nueva actitud del constituyente lo configura el art. 75 inc. 23 C.N. citado más arriba, que explícitamente recoge la noción, incluso a través del dictado de "medidas de acción positiva".

Históricamente, los referidos mecanismos, también conocidos como "acción afirmativa", surgieron en los Estados Unidos para combatir el flagelo de la discriminación racial.

Cabe mencionar que estas medidas apuntan a "discriminar para igualar", en particular respecto de cuatro colectivos identificados por la norma constitucional consignada: los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados.

Si se visualiza a la igualdad como una vara absoluta y rígida, no cabría aceptar ninguna discriminación

Por el contrario, desde una óptica realista y maximizadora de los derechos, podría llegar a tolerarse a la llamada "discriminación benigna", que da basamento a estas medidas de acción positiva.

7. DISCRIMINACIÓN INVERSA

Por llegar a proteger en forma normativa-objetiva un grupo de personas que en principio podría sufrir de discriminación se perjudica a otras personas que sufren en forma indiscriminada una desigualdad que evade todo análisis subjetivo de la cuestión aplicable. A esto se lo denominó "discriminación inversa".

Es decir, cuando se favorece a determinadas personas de ciertos grupos sociales en mayor proporción que a otras, con el objetivo de compensar y equilibrar la marginación o el relegamiento desigualitarios que recaen sobre aquellas personas que con la discriminación inversa se benefician. Sin embargo esta discriminación positiva debe ser razonable (6).

Esta práctica puede parecer, en principio, violatoria de la igualdad, pero por el contrario, es una herramienta razonable para alcanzar una solución subjetiva ante problemáticas que surgen del solo hecho regulador, porque tiende a superar la desigualdad discriminatoria del sector perjudicado.

Un claro ejemplo de este dispositivo ocurre con todas las leyes que establecen cupos obligatorios-objetivos al ingreso a ciertos lugares públicos o privados. Como puede ser la ley electoral federal, que fija el cupo o porcentaje mínimo de mujeres que los partidos deben incluir en las listas de candidatos a cargos electivos, conforme el propio art. 37, segundo párrafo, de la Constitución Nacional, sin tener en cuenta que en dicha situación el cargo podría estar ocupado por una persona del sexo opuesto con mayor idoneidad como marca la Constitución Nacional, pero siempre que para ello se utilice un análisis razonable de cada situación en particular.

(6) BIDART CAMPOS, ob.cit., t. I, p. 388.

Si bien tuvo su nacimiento en los EE.UU. en el famoso leading case "Parke Davis" en la Argentina tuvo su recepción en el fallo de la CSJN "Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c. Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas", del 24/10/2000 (7), donde sostuvo que la existencia de una obra social que deba cumplir el Programa Médico Obligatorio —resolución 247/96, MSyAS— no puede redundar en perjuicio de la afiliada y menos aún del niño, ya que si se aceptara la interrupción de su asistencia en razón de las obligaciones puestas a cargo de aquella entidad, se establecería un supuesto de *discriminación inversa* respecto de la madre del menor que, amén de no contar con prestaciones oportunas del organismo al que está asociada, carecería absolutamente del derecho a la atención sanitaria pública, lo que colocaría al Estado Nacional en flagrante violación de los compromisos asumidos en el cuidado de la salud.



CAPITULO V

EL PRINCIPIO DE RESERVA, LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. El debido proceso legal: "*due process of law*". Antecedentes históricos. — 3. Principio de reserva. — 4. Principio de legalidad. a) Génesis y desarrollo. b) Regulación normativa. c) Conflicto con normas internacionales. — 5. Principio de razonabilidad. a) Concepto y características. b) Clases o tipos de razonabilidades. c) Jurisprudencia. c.1) Corte Suprema de Justicia de EE.UU. c.2) Tribunal Constitucional Federal de Alemania. c.3) Corte Suprema de Justicia de la Argentina. d) El principio de razonabilidad en la Constitución Nacional. d.1) Constitución histórica de 1853-60. d.2) Reforma constitucional de 1994. e) Tratados internacionales con jerarquía constitucional. e.1) Declaración Universal de Derechos Humanos. e.2) Declaración Americana de Derechos Humanos. e.3) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. e.4) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. f) Ingerencia de los tratados internacionales de derechos humanos. g) Recapitulación del principio de razonabilidad.

1. INTRODUCCIÓN

A partir de la Carta Magna inglesa de 1215, se obligó a que toda discusión y decisión de cuestiones que contengan un interés público (sea en materia penal o tributaria) se realice en el parlamento —principio de reserva—, es decir, a través de la ley —principio de legalidad—.

En dicho período, no sólo nace el principio de reserva y de legalidad, sino también un antecedente del sometimiento del estado a un ordenamiento jurídico predeterminado, llamado posteriormente "Estado de derecho".

Al instaurarse el Estado de Derecho, no sólo se requiere que la pena tenga como fundamento la ley material sino asimismo, que las leyes penales sólo puedan ser producidas con la participación de la representación popular, con lo que termina insertándose el componente democrático de la noción de Estado de Derecho, y con ello el concepto democrático de la ley (1).

(7) Fallos 323:3229.

(1) JESCH, DIETRICH, *Ley y Administración*, Madrid, 1978, p. 133.

En concordancia con el modelo del derecho penal, se postuló para el derecho tributario la vigencia del principio de legalidad como necesario apoderamiento específico del Parlamento, y luego el principio de tipicidad de los distintos tributos que configura el principio de reserva de ley.

Este principio responde al concepto de legitimidad racional del poder, pues es la ley la que determina las conductas prohibidas o debidas; siendo el fin del principio de legalidad afianzar la seguridad individual, ya que dentro de la esfera de la libertad jurídica, todo lo que no está prohibido está permitido.

Pero con el avance del tiempo se observó que con la ley formal sola no alcanzó para regular los derechos y aquellas cuestiones de interés público, sino que ella además debía cumplir con el elemento axiológico de razonabilidad. Aquí se da la separación entre el debido proceso legal formal (principio de legalidad) y material (principio de razonabilidad).

2. EL DEBIDO PROCESO LEGAL: "DUE PROCESS OF LAW"

La primera mención de este derecho fundamental en un texto constitucional se va a dar en los EE.UU., de la mano de lo prescripto en la Quinta Enmienda de la Constitución Federal de dicho país. En esta Enmienda, aprobada en 1791, se dirá, entre otras cosas, que "...a ninguna persona se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal...". Esta prescripción inicial fue posteriormente completada con lo dispuesto por la Enmienda Catorce adoptada en 1868 luego de la Guerra Civil (y dentro del proceso al cual se denominó nacionalización de algunos derechos fundamentales) en donde se señala que: "...ningún estado podrá privar a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal...".

En la Constitución Nacional se contemplan ambos aspectos—atento que una ley debe respetar estos dos parámetros y no uno solo de ellos: el adjetivo en el art. 17 y 18 y, el sustantivo en el art. 28—. Sin embargo, la razonabilidad legal es una garantía innominada, aunque sus elementos básicos estén dentro de ella: Bienestar general, salubridad, seguridad, etc. (Preámbulo, arts. 14, 14 bis, 16 y correlativos). En el derecho norteamericano se llama *balance of convenience rule* (regla del equilibrio conveniente).

No basta que una ley sea dictada de conformidad al procedimiento que la Constitución dispone y dentro de las facultades propias que le confiere al Congreso para que sea válida, pues debe también respetar los valores que la Constitución establece. Es decir, que el debido proceso sustantivo implica una garantía de ciertos contenidos y un patrón o estándar axiológico de razonabilidad.

Por eso, es necesario dar cobertura material de justicia al principio formal de legalidad, para lo cual es necesario acudir al valor justicia.

De esta forma el principio de legalidad quedaría diseñado de la siguiente manera: nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley justa no manda ni privado de lo que la ley justa no prohíbe.

3. PRINCIPIO DE RESERVA

Del art. 19 de la Constitución Nacional surge que toda nuestra organización política y civil reposa en la ley; los derechos y obligaciones de los habitantes así como las penas de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas, y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca (2).

Es decir, mientras que el principio de reserva habla de las facultades potestativas de un poder del estado, el principio de legalidad solo habla del instrumento que desarrolla la función del poder del estado, que siendo el poder legislativo, lo proyecta hacia la ley, en sus aspectos formales y materiales.

En un sistema democrático como el nuestro, se impone al Estado una actitud imparcial frente a los gobernados, aún cuando éstos profesen cultos que la mayoría rechace; ello está instituido por el art. 19 de nuestra Ley Fundamental, en el sentido que le dieron los constituyentes. Todas las acciones privadas de los hombres afectan de algún modo a los terceros, y si no se considera la existencia de éstos, tampoco podría concebirse la ofensa al orden y la moral pública (3).

Este principio se da en muchas ocasiones en la interpretación y resolución de normas tributarias. Como el ordenamiento jurídico argentino reconoce como principio fundamental el de reserva de ley, los tributos—como el que crea la ley 23.898—, sólo pueden ser sancionados por el órgano al que la Constitución Nacional le ha confiado la atribución de ejercer el poder tributario, es decir el Congreso de la Nación, por lo que resulta obvio que el único órgano con facultades para establecer exenciones impositivas, es ese mismo Congreso, desde que el poder de imponer "involucra al poder de desimponer", como lo recordó el Juez Marshall al votar la causa "Mc Culloch v. Maryland", resuelta por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América del Norte (4) y lo ha señalado concordantemente la más autorizada doctrina nacional (5).

La Constitución Nacional consagra el principio de reserva de ley en la parte dogmática cuando se refiere en el art. 4º, a las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población impone el Congreso, y al atribuirle esas facultades en forma exclusiva al Congreso en el art. 17 (6).

(2) Fallos 311:2553, del 01/12/1988.

(3) Fallos 312:496, del 18/04/1989.

(4) 4 Wheat, 316, 404 (1819).

(5) GIULIANI FONROUGE, CARLOS MARÍA, *Derecho Financiero*, 3ª ed., Buenos Aires, 1977, t. I, p. 289.

(6) Art. 17 de la Constitución Nacional: "...sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el art. 4º".

Sin embargo, también es necesaria la intervención del Congreso (art.14) para disponer o restringir las garantías, derechos y libertades que aseguran los arts. 18 y 19 de la C.N.; por lo que puede colegirse que ambas normas —arts. 17 y 19 de la C.N.— concurren a delimitar el principio de reserva legal tributaria.

La Corte Suprema en reiteradas oportunidades ha sostenido que el principio de reserva de ley tributaria es de rango constitucional y es propio del estado de derecho, por lo que solo admite que la ley formal tipifique el hecho que se considera imponible y que constituiría la posterior causa de la obligación tributaria (7). Tal doctrina coincide con antiguos precedentes donde se sostuvo que la facultad atribuida al Congreso para crear impuestos constituye uno de los rasgos esenciales del régimen representativo y republicano de gobierno (8).

En virtud de este principio se requiere que todo tributo sea sancionado por ley material y formal, entendida ésta como la disposición que emana del órgano constitucional que tiene la potestad legislativa, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución para la sanción de las leyes (9). Señala Luqui que la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a que no se pueden establecer tributos sin ley, toma a este término en su acepción amplia, que incluye a los impuestos, las tasas y las contribuciones (10). Ha dicho la Corte Suprema que así como es únicamente admisible que el Poder Legislativo por medio de una norma jurídica con naturaleza de ley formal establezca impuestos, contribuciones y tasas, debe aquélla regla con entidad para crear obligaciones contener los elementos esenciales del hecho imponible, entre los cuales se encuentra la determinación de la base (11).

En el Derecho tributario formal este principio no rige con la misma intensidad, ya que este sector se refiere a la actuación de la Administración, a la gestión que realiza para aplicar los impuestos en cada caso concreto y también las formas de verificación, fiscalización y recaudación; funciones que se engloban en la atribución que la Constitución otorga al Poder ejecutivo para recaudar las rentas, conforme al art. 100, inc. 7 de la C.N.

4. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

a) Génesis y desarrollo

El denominado principio de legalidad, resulta esencial al Estado de Derecho, y postula el sometimiento del estado moderno no sólo a la norma jurídica

(7) CS, Fallos 294:152.

(8) CS, Fallos 155:293; 182:412.

(9) GARCÍA BELSUNCE, HORACIO, *Las garantías constitucionales del contribuyente-Temas Tributarios*, Buenos Aires, 1982, ps. 75-131.

(10) LUQUI, JUAN CARLOS, "Las garantías constitucionales de los derechos de los contribuyentes", LA LEY, 142-891.

(11) CS, Fallos 318:1154; 219:3400, entre muchos otros.

ca en sentido formal, sino a todo el ordenamiento jurídico, entendido como una realidad dinámica (12).

Según el principio de legalidad debe ser el órgano investido del Poder Legislativo el que brinde a los individuos pautas inequívocas acerca de cuáles conductas están prohibidas y cuáles permitidas (13).

El principio de legalidad —arts. 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional— veda a los poderes públicos —entre los que se encuentran los jueces de la Nación— ejercer sus facultades más allá de las atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico (14).

Aunque este principio ya había sido receptado en el Acta capitular del Cabildo de 1810 donde se estableció que no podían imponerse contribuciones ni gravámenes al pueblo o a sus vecinos sin previa consulta y conformidad del Excelentísimo Cabildo; fue reiterado en el Reglamento de la Junta Conservadora de 1811, por el proyecto de Constitución de 1813 y en las Constituciones de 1819 y 1826; el art. 18, inc. 4 del proyecto de Alberdi establecía que sólo el Congreso impone las contribuciones. Bien ha dicho Luqui que en nuestro país el principio de legalidad tributaria nació con la independencia (15).

En el derecho penal reviste singular trascendencia la regla cardinal de irretroactividad de la ley (*tempus regit actum*), emanación del principio de legalidad contenido en el art. 18 de la Constitución Nacional, el cual se expresa en el principio *nullum crimen nulla poena sine lege*, según el cual el juez penal debe aplicar la ley que se hallaba vigente al tiempo de producirse la conducta delictiva (16).

La CSJN en el precedente "Provincia de Tierra del Fuego c. Nación" (17) sostuvo que los arts. 4º, 17 y 75 de la Ley Fundamental imponen el principio de legalidad en materia tributaria, criterio que reiteró en "La Bellaca" (18). Sin embargo, en el fallo "Generoso Mazza" (19) se refiere a los arts. 18 y 19 de la C.N. al señalar que la obligación tributaria se ajusta al principio de legalidad (20).

Tanto el actuar de la Administración como los deberes de los contribuyentes, responsables y terceros resultan no siempre de ley formal, sino de reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo; lo que es consecuencia de la

(12) Fallos 319: 2005.

(13) Fallos 316: 2797.

(14) Fallos 317:509.

(15) LUQUI, JUAN CARLOS, *Derecho Constitucional Tributario*, Buenos Aires, 1993, p. 33.

(16) CSJN in re: "Jofré, Teodora s/ denuncia", del 24/08/2004. Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Adolfo Roberto Vázquez y E. Raúl Zaffaroni, Fallos:.....

(17) CS, Fallos 321:1888.

(18) CS, Fallos 316:115.

(19) CS, Fallos 312:447.

(20) Esta cuestión dio lugar hace muchos años a una discusión académica entre los Dres. Jarach y Giuliani Fonrouge, pues el primero ubicaba el principio de legalidad tributaria básicamente en el art. 17 de la C.N., mientras que para el segundo se encontraba en el art. 19 que establece que "ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe".

86

distribución del poder tributario que efectúa la Constitución entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, al que parece otorgarle atribuciones propias en materia de recaudación. Sin embargo, el actuar de la Administración también debe acomodarse a la ley y solo puede desarrollarse en la medida en que aquélla la habilita; ya que en el campo del Derecho Administrativo, del Procesal y del Tributario adjetivo, rige el principio de legalidad, que es un principio general del Estado de Derecho.

b) Regulación normativa

El principio de legalidad se encuentra regulado en el art. 18 de la Constitución Nacional, "...Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en que casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice..."

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José de Costa Rica", art. 9º: "...Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello..."

Y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 15: 1. "...Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que aplicación en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello".

Complementa el inc. 2, estableciendo que nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

c) Conflicto con normativas internacionales

En el caso "Arancibia Clavel" (Fallos: 327:3312), se produjo un conflicto entre principios y derechos nacionales y la aplicación del derecho de gentes.

La disidencia de dicho fallo, efectuada por el juez Carlos Fayt fue a nuestro criterio el que mejor ha resuelto esta cuestión, estableciendo la superioridad del principio de legalidad (21).

El Juez textualmente dijo que "... la aplicación de la costumbre internacional a fin de atribuir imprescriptibilidad a las conductas imputadas por su calidad de crímenes de lesa humanidad, contrariaría las exigencias de que la ley penal deba ser cierta —exhaustiva y no general—, estricta —no analógica— y, concretamente en relación al sub lite, escrita —no consuetudinaria—, pues las fuentes difusas —como característica definitoria de la costumbre internacional— también son claramente incompatibles con el principio de legalidad..."

5. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD

a) Concepto y características

Etimológicamente, razonabilidad o razonable proviene del latín *rationabilis* que significa arreglado, justo, conforme a razón. Y si recurrimos al Diccionario de la Real Academia Española (RAE), nos dice que la razón es la facultad de discurrir. Con todos estos elementos decimos como primera idea, que el examen de razonabilidad es todo aquello que nuestra sana facultad de discurrir nos indica que es justo.

Bidart Campos nos señala que el principio de razonabilidad —derivado de los arts. 28 y 33 de nuestra Carta Magna— importa, dentro de nuestro sistema constitucional, la exclusión de toda arbitrariedad o irrazonabilidad, en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos. Ello quiere decir que existe un patrón, un criterio, un estándar jurídico, que obliga a dar a la ley —y a los actos estatales de ella derivados inmediata o mediatamente— un contenido razonable, justo, valioso, de modo que alguien puede ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley prohíbe, siempre que el contenido de esa ley sea razonable, sea justo, sea válido.

Por otra parte, Sabsay y Onaindia consideran que la alteración de un derecho por vía reglamentaria constituye un ejercicio irrazonable de esa potestad ya que lo priva de su esencia. La cuestión radica en determinar cuándo se da esa situación.

Padilla afirma que los derechos se limitan como única manera de poder vivir en sociedad y las restricciones que dispongan en cuanto a su goce, no deben exceder de lo indispensable para ese fin, esto es, hacer compatible la libertad de cada uno con la de los demás. Mientras se atiende a ese criterio, la limitación es "justa" y por ende "razonable"; en cuanto se lo deje de lado, surge el elemento irrazonable. La reglamentación de los derechos persigue

(21) V. CARNOTA, WALTER F., Conferencia en la Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba, noviembre de 2006.

finés, y para alcanzarlos se vale de medios, que deben resultar proporcionales a aquel fin. Debe existir siempre una adecuada relación entre fines y medios, una equivalencia entre las finalidades que propongan una norma y los mecanismos, procedimientos o caminos que establezcan para llegar a ellas.

Así, tenemos que toda norma jurídica debe ser razonablemente justa tanto en su aspecto formal como material para tener fuerza ordenatoria y ejemplificadora y ser cumplidas por todos nosotros, sumado a que si además se pretende reglamentar un derecho se debe desarrollar sobre la base de un fin social sin destruir ningún derecho al amparo de nuestra constitución, pero para llegar a esos fines los medios que se utilicen deben tener una razonable adecuación con ellos.

b) Clases o tipos de razonabilidad

Como inicio, debemos decir que el principio de razonabilidad no es un principio autónomo, es decir, no ha nacido y no se ha desarrollado con vida propia, sino por el contrario es un principio que pertenece a un instituto genérico llamado "due process of law". Pero la razonabilidad no la tenemos que buscar en todos los aspectos del debido proceso legal, sino en uno de ellos que es su aspecto sustantivo y no su aspecto adjetivo, que regula el principio de legalidad.

De acuerdo con las denominaciones utilizadas por Juan F. Lináres, la razonabilidad es la adecuación de sentido en que se deben encontrar todos los elementos de la acción para crear derecho: los motivos (circunstancias del caso), los fines el sentido común jurídico (el plexo de valores que lo integran) y los medios (aptos para conseguir los fines propuestos).

Si la razonabilidad de las leyes es la adecuación de todos sus factores con el sentido constitucional, esto significa que tanto las circunstancias del caso tenidas en cuenta por el legislador, como los medios elegidos y los fines propuestos, deben guardar una proporción entre sí (razonabilidad interna del acto) y además que las leyes deben ajustarse al sentido constitucional formado por los motivos tenidos en cuenta por el constituyente, por los fines propuestos, por los valores jurídicos fundamentales y por los medios previstos (razonabilidad externa del acto).

En consecuencia, la razonabilidad puede ser interna o externa, según que la adecuación entre los distintos elementos de la acción (relación medio-fin) se dé dentro de la ley o entre la ley y la Constitución:

b.1) Razonabilidad interna de la ley

Se da como razonabilidad técnica social cuando los motivos sociales determinantes (de acuerdo con las circunstancias del caso) hacen que el legislador tome medidas (medios) proporcionadas al fin social propuesto.

La razonabilidad técnica social es una simple relación de adecuación entre motivos, medios y fines pero no implica necesariamente la justicia de la medida, esto forma parte de la razonabilidad jurídica.

b.2) Razonabilidad externa de la ley

Es más compleja que la anterior, se da en principio como razonabilidad jurídica. El acto legislativo razonable internamente, debe satisfacer el sentido común jurídico de la comunidad expresado en el plexo de valores que lo integra; valores que son recibidos, de acuerdo con las modalidades de cada pueblo y por la constitución del Estado.

La razonabilidad jurídica presenta las siguientes modalidades:

- **Razonabilidad de la ponderación:** Se presenta en las leyes cuyas prestaciones guardan una relación de equivalencia con la sanción prevista para el caso de incumplimiento.

- **Razonabilidad de la selección:** Se presenta en las leyes que respetan la igualdad, de forma tal que, frente a circunstancias equivalentes, la prestación y la sanción es la misma y solo cuando las circunstancias son diferentes es razonable que las prestaciones o las sanciones sean diferentes.

- **Razonabilidad en los fines:** Se da cuando los fines de la ley, o las medidas dispuestas por ella, no violan los fines previstos en la Constitución. Por ejemplo, no es razonable que una ley impositiva grave la propiedad en una proporción tal que implique la confiscación del bien, pues ello está expresamente prohibido en la Constitución Nacional.

c) Jurisprudencia

c.1) Corte Suprema de Justicia de EE.UU.

Entre los años 1877 y 1887 la Corte Suprema de los EE.UU. sostenía que el remedio contra las malas leyes debía buscarse en las urnas y no ante los jueces; pero luego comenzó a utilizarla como garantía contra la arbitrariedad de los órganos legislativos. A fines del siglo XIX el concepto de debido proceso había ganado en profundidad y en extensión. De mera garantía procesal comenzó a tener aplicación como garantía sustancial que limita también al órgano legislativo.

En el derecho constitucional estadounidense, los alcances del control de razonabilidad dependen del derecho constitucional afectado. En efecto, la Corte Suprema distingue entre el ejercicio del control de razonabilidad de leyes que incursionan en el ámbito socio-económico y que afectan derechos de naturaleza económica ("economic rights") en especial el derecho de propiedad y la libertad contractual, y el ejercicio del control de razonabilidad de leyes que afectan derechos de naturaleza no económica ("non-economic rights"), entre los que se encuentran el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, la libertad religiosa y otros derechos fundamentales.

El origen de esta distinción se remonta a la célebre nota al pie núm.4 del Juez Stone en el fallo "Carolene Products". En este caso, la Corte Suprema estadounidense estableció una fuerte presunción de constitucionalidad de

las regulaciones socio-económicas y subrayó que no iba a declarar inconstitucional una regulación socioeconómica por falta de adecuación entre el medio elegido y los fines perseguidos, a menos que dicha regulación careciera de toda base racional ("rational basis").

En lo concerniente a la protección constitucional del derecho de propiedad y de la libertad contractual en el derecho estadounidense, se pueden observar—en el siglo XX—dos etapas claramente diferenciadas: a) la primera etapa conocida con la era "Lochner (1905)" o "pensamiento legal clásico" (también conocido como "formalismo"), en donde la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia consideró la libertad contractual como una "libertad fundamental" y declaró la inconstitucionalidad de aquellas regulaciones que importaban—según la concepción de esa época—una intromisión estatal en el ámbito privado; b) una segunda etapa, en donde se deja de lado y se repudia la jurisprudencia de la era "Lochner", admitiéndose la intervención del estado en la economía y en las relaciones contractuales privadas por razones de interés general.

De este modo los EE.UU. abandonaron la idea liberal sin limitaciones y la ubicaron dentro de un Estado de Derecho, con una compatibilización absoluta con los principios, derechos y garantías enunciados en su Constitución.

c.2) Tribunal Constitucional Federal alemán

El derecho alemán posee un principio equivalente al debido proceso procesal o adjetivo. Se trata del *faïres verfahren*, o derecho a un procedimiento honesto y justo, fundamentado constitucionalmente en el principio del Estado de Derecho el cual exige, en el ámbito jurisdiccional, un proceso guiado por los postulados de la justicia y equidad. El contenido de ese principio es similar al procesal *due process of law* americano: garantía del juez natural, derecho al contradictorio, publicidad, presunción de inocencia, entre otros.

Ya en los casos que el derecho norteamericano enfrenta utilizando el sustantivo *due process of law* son normalmente tratados por la jurisprudencia alemana en los cuadros del principio de la proporcionalidad.

En Alemania, el control de razonabilidad también (como en EE.UU.) fue instituido a partir de un desarrollo jurisprudencial del BverfG, operando durante la década del 60, aunque como freno a los abusos de las legislaciones arbitrarias y rompiendo el dogma de la intangibilidad del legislador. El principio de proporcionalidad tiene sus comienzos al final del 50 en la teoría jurídica alemana, pero abarcaba sólo aquello que actualmente se designa como el subprincipio de necesidad.

En el caso germánico, la construcción del concepto de principio de la proporcionalidad o principio de la prohibición en exceso, ni siquiera tuvo como base una cláusula expresa de la Ley Fundamental, siendo que ese principio fue entendido como una derivación necesaria de la propia idea de Estado democrático de derecho.

El principio de proporcionalidad en su forma actual, es normalmente descripto por la doctrina alemana como un conjunto de tres subprincipios:

1. *Adecuación*: El primer subprincipio establece la exigencia de la conformidad o adecuación entre medios y fines, según el cual el acto debe ser apropiado para la realización de las finalidades a él subyacentes.

2. *Necesidad*: El segundo subprincipio es el de la exigibilidad o necesidad, que traduce del derecho del ciudadano a la menor restricción posible a su derecho. El medio empleado por el legislador debe ser adecuado y necesario para alcanzar el objetivo buscado. El medio es adecuado cuando con un auxilio se puede alcanzar el resultado deseado; es necesario cuando el legislador no podría haber elegido otro medio, igualmente eficiente, pero que no limitase de forma sensible el derecho fundamental.

3. *Proporcionalidad en sentido estricto*. El tercer subprincipio es el de la justa medida o de la proporcionalidad en sentido estricto. La exigencia norteamericana de que los fines de la norma sean legítimos parece tener su correspondiente correlato en este subprincipio.

Aunque sean todos ellos subprincipios constitutivos como dice Canotilho, hay consenso entre los autores en admitir que el principio de proporcionalidad está formado por la combinación de los tres elementos mencionados.

Ahora bien, aunque existan coincidencias entre la teoría alemana y la norteamericana, Juan Vicente Sola dice se puede notar una gran diferencia de enfoque entre ambas, donde la de EE.UU. se centra en cuestiones primordialmente políticas, con la búsqueda de un equilibrio de intereses que pueda garantizar la legitimidad de las decisiones, mientras que aquella manifiesta preocupaciones semejantes por medio de un lenguaje de teoría de los sistemas, buscando un equilibrio de valores jurídicos—no de intereses políticos—que garantice la consistencia del sistema jurídico, más que su representación. Mientras la aceptación de una restricción, para la Suprema Corte, está vinculada a su adecuación a los valores previstos en la Constitución porque son dominantes en la sociedad, parece que la principal preocupación de la Corte Constitucional Federal Alemana—BverfG—es el mantenimiento de la armonía intrasistémica.

c.3) Corte Suprema de Justicia de Argentina

En idéntico sentido que en la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos, se evidencia en los fallos de la Corte Argentina una marcada actitud de deferencia al juicio que realiza el Poder Legislativo sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de una determinada regulación socio-económica marcada como una cuestión política no revisable o no demasiado revisable por el Poder Judicial por la presunción de constitucionalidad que ella reviste.

Sin embargo, nuestro Máximo Tribunal tiene dicho que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realiza-

ción procuran o cuando consagran una manifiesta iniquidad, y el principio de razonabilidad debe cuidar especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte de su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Ley Fundamental.

d) El principio de razonabilidad en la Constitución Nacional

d.1) *Constitución histórica de 1853-60*

Como bien se ha señalado el principio de razonabilidad es una garantía innominada que deriva del art. 28 y 33 de la Constitución Nacional en conjunción con los arts. 16, 17 y el preámbulo de la Constitución Nacional.

Sin embargo, el test de razonabilidad comienza en el art. 28 y decimos que la reglamentación de un derecho por medio de una determinada ley, decreto o resoluciones resulta irrazonable cuando "altera" los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos 1º al 27 de la Constitución Nacional.

Y es justamente es en la palabra "alterar" la que derivan todos y cada uno de los elementos del principio de razonabilidad (alteración en los medios, en los fines y en la axiología jurídica, arts. 16, 17 y el preámbulo de la CN).

Pero si queremos saber qué tipo de alteración se refiere el art. 28, la respuesta la encontramos en el art. 99 inc. 2 (anterior art. 86 inc. 2), donde establece que todas las instrucciones y los reglamentos que expida el Poder Ejecutivo Nacional, para la ejecución de las leyes de la Nación, no podrán alterar el "espíritu" de estas últimas. Si bien ésta debería aplicarse tan solo a los decretos, no encontramos obstáculo alguno para que sea utilizado para todo tipo de normativa regulatoria de los principios, derechos y garantías enunciados en la Constitución Nacional, como por ejemplo las leyes, resoluciones, acordadas, sentencias.

Ello tiene como interpretación lógica que ninguna regulación por más importante y necesaria que sea puede aniquilar o destruir un derecho constitucional en su esencia misma, en su principio generador o en su carácter íntimo.

Por lo tanto, la circunstancia de que los poderes constituidos obrasen en ejercicio de facultades reglamentarias, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, puesto que es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades lo que le va a otorgar validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dicha exigencia, para no alterar la voluntad de los poderes constituyentes.

d.2) *Reforma constitucional de 1994*

En el art. 43 se ha plasmado constitucionalmente la garantía de "amparo", para proteger a las personas de todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o

amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley.

Como se puede notar el principio de razonabilidad tiene en la acción de amparo la garantía más importante para su protección, si tenemos en cuenta que por esta vía se protegen todos los actos arbitrarios o ilegales de las autoridades públicas.

Entendemos como arbitrario a todo acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho. He aquí una cadena ininterrumpida donde todo lo arbitrario es irrazonable, y todo lo irrazonable es inconstitucional porque altera o destruye un derecho constitucional, con la consecuencia lógica de la declaración de inconstitucional de dicha normativa.

e) Tratados internacionales con jerarquía constitucional

Además de ello, al haberse otorgado jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos a través del art. 75 inc. 22 de la CN conformando el denominado por la doctrina "bloque constitucional", deben analizarse también los elementos otorgados por los doce tratados internacionales de derechos humanos para poder complementarlos con la Constitución Nacional.

e.1) *Declaración Universal de Derechos Humanos*

Art. 9º. Nadie podrá ser *arbitrariamente* detenido, preso ni desterrado.

Art. 12. Nadie será objeto de ingerencias *arbitrarias* en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ingerencias o ataques.

Art. 15. [...] 2º) A nadie se privará *arbitrariamente* de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Art. 17. [...] 2º) Nadie será privado *arbitrariamente* de su propiedad.

Art. 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación *razonable* de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

e.2) *Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José de Costa Rica"*

Art. 7º. Derecho a la libertad personal

3º) Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento *arbitrarios*.

5º) Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judi-